

다. 가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물권변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다.⁷⁰⁶⁾

따라서 가등기상의 권리로서 압류명령의 대상이 될 수 있는 것으로는 소유권이 전청구권가등기상의 소유권이전등기청구권, 조건부소유권이전가등기상의 조건부 소유권이전등기청구권 등이 있다.

라. 가등기상의 권리에 대한 집행의 관할도 제1차적으로는 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원이고, 등기를 하는 곳(민집규 제175조 제2항)은 제2차적 관할에 불과하다. 이 경우 제3채무자로서는 가등기의 본등기의무자를 적어야 할 것이다.

706) 대법원 1998. 11. 19. 선고 98다24105 전원합의체 판결【판결요지】가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물권변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다고 보아야 한다.

제8절 채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행

I. 서

1. 채권을 목적으로 하는 담보권의 실행 또는 물상대위권의 행사 및 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행은 원칙적으로 이러한 권리에 대한 강제집행에 준하여 이루어진다.

여기서 채권이란 금전의 지급 또는 선박이나 동산의 인도를 목적으로 하는 채권을 말하고,⁷⁰⁷⁾ 그 밖의 재산권이란 부동산·선박·동산·채권 이외의 재산권을 말한다.

2. 채권 및 그 밖의 재산권에 담보권의 실행에 대하여는 종래 그 중 질권에 관해서만 실체법상의 채권추심권이 있고, 그 밖에는 절차상 채권 등 집행에 의한 배당 절차에서 우선권에 의하여 권리의 만족을 얻을 수 있었다. 담보권 중 우선특권의 실행에 관해서는 실체법적인 규정은 없고, 구 경매법에도 아무런 규정이 없었으나, 민사집행법은 개정 전의 민사소송법과 마찬가지로 민사집행법 제273조에서 실체법과 별도로 절차상 질권 및 우선특권, 물상대위권의 행사로서의 요건을 정하고 우선특권에 관해서도 그 우선변제권을 실현하기 위한 절차의 내용을 명확하게 하고 있다.

채권을 목적으로 하는 담보권으로서는 질권이 있고, 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권에는 특허권 등의 지적재산권 질권이 있다.

권리질권은 질권자가 질권의 목적이 된 채권 그 밖의 재산권을 직접 청구하거나(민법 제353조), 민사집행법이 정한 집행방법에 의하여 이를 행사할 수 있다(민법 제354조). 성질상 지명채권과 지시채권에 대한 질권의 경우에는 그 채권을 직접 청구할 수 있을 것이나,⁷⁰⁸⁾ 그 밖의 재산권, 예컨대 특허권 등이나 사원의 지분권 등을 목적으로 하는 질권의 경우는 그 재산권을 직접 청구할 수는 없으므로 강제집행의 방법에 의할 수밖에 없다.

707) 다만 동산집행의 대상인 어음·수표·화물상환증 등의 유가증권에 화체되어 있는 것을 제외한다.

708) 대법원 2005. 2. 25. 선고 2003다40668 판결【판결요지】질권의 목적이 된 채권이 금전채권인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있고, 채권질권의 효력은 질권의 목적이 된 채권의 지연손해금 등과 같은 부대채권에도 미치므로 채권질권자는 질권의 목적이 된 채권과 그에 대한 지연손해금채권을 피담보채권의 범위에 속하는 자기채권액에 대한 부분에 한하여 직접 추심하여 자기채권의 변제에 충당할 수 있다.

3. 담보권은 그 목적물이 멸실·훼손 또는 공용징수로 인하여 담보권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있는바, 이와 같은 담보권자의 물상대위권 행사도 강제집행에 의한 권리질권의 행사와 같은 방법에 의한다.

4. 한편 2010. 6. 10. 법률 제10366호로 동산·채권 등의 담보에 관한 법률(이하 '동산채권담보법'이라고 부른다)이 제정되고 2012. 6. 11.부터 시행됨으로써 채권 담보권의 실행절차가 정립되었으므로 이에 관하여도 설명한다.

II. 질권의 실행

1. 강제집행 규정의 준용

채권 그 밖의 재산권에 대한 질권의 실행을 위한 집행절차에는 채권과 다른 재산권에 대한 강제집행에 관한 민사집행법과 민사집행규칙의 규정이 대체로 준용된다(민집 제273조, 민집규 제200조).

따라서 집행법원이 질권의 목적인 채권 그 밖의 재산권을 압류하여 추심명령, 전부명령이나 특별현금화명령에 의하여 현금화하고 그 현금화한 대금을 배당하게 된다. 다만 질권자에게는 직접 추심권이 부여되어 있으므로 그것에 의하여 목적을 달성할 수 없는 경우에만 강제집행의 방법에 의한다. 따라서 압류 후의 현금화를 위한 방법으로는 추심명령의 수단을 취할 것으로 생각하기는 어렵고 전부명령이나 특별현금화방법이 이용된다.

2. 집행절차의 특수성

가. 신청절차 등

1) 질권의 실행을 위하여 압류명령을 신청함에 있어서는 집행권원을 요하지 않지만 질권자는 집행법원에 대하여 그 대신 담보권, 즉 질권의 존재를 증명하는 서류를 제출하여야 하고, 특히 질권의 목적인 권리가 특허권 등과 같이 권리의 이전에 관하여 등기나 등록을 요하는 경우에는 그 등기사항증명서 또는 등록원부의 등본을 제출하여야 한다(민집 제273조).

2) 담보권의 승계가 있는 때에는 승계를 증명하는 서류를 붙여야 하고, 압류명령을 채무자에게 송달할 때에는 그 서류의 등본을 함께 송달하여야 한다(민집규 제200

조, 민집 제264조).

3) 신청서에는 채권자·채무자·질권설정자 및 제3채무자가 있는 때에는 제3채무자를 적고, 그 외에 질권과 피담보채권의 표시, 질권의 목적인 권리의 표시, 피담보채권의 일부에 대한 질권의 실행인 경우에는 그 취지 및 범위를 기재하여야 한다(민집규 제192조, 제200조). 피담보채권의 채무자와 질권설정자(담보제공자)가 다른 물상보증의 경우에는 질권설정자(질권의 목적인 채권의 채권자)가 여기서 채무자에 해당한다. 질권자는 질권의 내용으로서 목적채권에 대하여 질권의 설정과 그 대항요건을 갖춘 뒤에 이루어진 처분행위를 무시하고 우선변제를 받을 수 있는 권리를 가지고 있으므로 채무자 및 제3채무자에 대하여 다시 처분을 금지하는 취지의 압류명령을 발하는 것은 그것만으로는 무의미하지만, 현금화명령의 전제로서 압류명령이 필요하다고 해석된다.

4) 권리질권 또는 물상대위권의 행사에 있어서 강제집행절차에 관한 규정 중 성질상 준용할 수 없는 것은 그 적용이 배제된다. 예컨대 압류금지채권에 관한 민사집행법 제246조 제1항 내지 제3항의 규정은 준용의 여지가 없다. 다만 채권의 압류를 금지하는 규정 중에는 동시에 질권의 설정도 금지하는 경우가 있다(공무원연금법 제32조, 군인연금법 제7조 등).

5) 강제집행의 경우에는 제3채무자는 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁하여 채무를 면할 수 있으나(민집 제248조), 그 채권이 질권의 목적인 경우에는 제3채무자는 질권자의 승낙이 없는 한 공탁에 의하여 채무를 면할 수 없다. 질권자는 채권을 직접 추심할 수 있는 권리가 있고(민법 제353조), 이러한 권리는 압류 후에도 존속하기 때문이다.

6) 또 질권에는 우선변제권이 있으므로 질권실행을 위한 압류가 된 경우에는 그 목적인 권리에 대하여 압류의 경합이나 배당요구가 있는 때에도 질권자를 위하여 전부명령이나 양도명령을 할 수 있다. 이는 질권자에 의한 압류가 다른 채권자에 의한 압류나 배당요구의 뒤에 이루어진 경우에도 마찬가지이다.

7) 주식의 약식질권자가 주식의 소각대금채권에 대하여 물상대위권을 행사하기 위하여는 민법 제342조, 제355조, 민사집행법 제273조 제2항, 제3항에 의하여 질권설정자가 지급받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 하나, 한편 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제58조 제1항에서 개별집행절차개시를 금지하는 규정을 둔 목적의 하나는 회생채권과 회생담보권 모두가 회생절차에 따라야 한다는 회생

절차의 기본구조를 뒷받침하려는 데 있으므로 회생절차개시결정이 있는 후에는 물상대위권의 행사를 위한 압류의 허용 여부와는 별도로 추심명령은 그 효력을 발생할 수 없다.⁷⁰⁹⁾

8) 예탁증권등에 대한 질권실행을 위한 신청서에는 민사집행규칙 제192조에 기재된 사항에 외에 예탁결제원 또는 예탁자를 표시하여야 한다(민집 제201조 제3항, 제200조 제2항).

예탁증권등지분에 대하여 질권이 설정된 경우, 예탁결제원 또는 예탁자는 예탁증권등지분에 관한 질권자의 청구가 있는 때에는 그 이해관계 있는 부분에 관한 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부의 사본을 교부하여야 한다(민집규 제201조 제1항). 예탁증권등에 대한 질권의 실행을 위한 신청서에는 그 질권에 관한 기재가 있는 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부의 사본을 붙여야 한다(민집규 제201조 제2항).

예탁증권등에 관한 담보권의 실행에 관하여는 민사집행규칙 제201조 제3항에서 예탁증권등집행에 관한 규정을 대폭 준용하고 있다. 예탁증권등에 관한 질권의 실행방법으로는 집행법원이 압류명령을 발하여 집행법원의 현금화를 위한 예탁증권등지분양도명령 또는 매각명령에 의하여 현금화를 행하는 방법 외에도 질권자가 질권의 목적인 예탁증권등에 관하여 예탁결제원 또는 예탁자로부터 증권의 반환을 받아 이를 집행관에게 제출하여 유체동산으로서의 경매를 신청할 수도 있다. 또 예탁증권등에 대한 질권에 관하여 질권설정계약과 동시에 유질계약이 되어 있는 경우에는 질권자는 유질의 설정으로서 질권계좌로부터 자기 또는 매수인의 계좌로의 계좌대체를 행하거나 증권을 반환받을 수 있다. 예탁증권등의 일부만에 대하여 담보권을 실행하는 경우에는 압류명령신청서에 목적물의 표시를 할 때에 그 범위를 분명히 하여야 하고, 피담보채권의 일부에 관하여 담보권의 실행을 할 경우에도 압류명령신청서에 그 뜻과

709) 대법원 2004. 4. 23. 선고 2003다6781 판결【판결요지】[1] 주식의 약식질권자가 주식의 소각대금채권에 대하여 물상대위권을 행사하기 위하여는 민법 제342조, 제355조, 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조 제2항, 제3항에 의하여 질권설정자가 지급받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 하나, 한편 회사정리법 제67조 제1항에서 개별집행절차개시를 금지하는 규정을 둔 목적의 하나는 정리채권과 정리담보권 모두가 회사정리절차에 따라야 한다는 회사정리절차의 기본구조를 뒷받침하려는 데 있으므로 회사정리절차개시결정이 있는 후에는 물상대위권의 행사를 위한 압류의 허용 여부와는 별도로 추심명령은 그 효력을 발생할 수 없다. [2] 법원이 특정 정리채권(담보권)을 변제하지 아니하고서는 회사의 갱생에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정하여 회사정리법 제112조의2 제2항에 따라 정리절차에 의하지 아니한 변제를 허가하였다 하더라도, 그 효과는 같은 법 제112조에서 정한 정리채권 소멸금지의 효력이 해제됨에 그칠 뿐이고, 허가받은 내용대로 변제가 이루어지지 아니한 경우에 정리절차와 무관하게 개별적인 권리행사에 나아갈 수 있는 것은 아니다.

범위를 적어야 한다.

압류명령은 채무자와 예탁결제원 또는 예탁자에게 송달하여야 하고(민집규 제182조 제1항, 민집 제227조 제2항), 압류명령이 예탁결제원 또는 예탁자에게 송달되면 그때의 압류의 효력이 생기며(민집규 제182조 제1항, 민집 제227조 제3항), 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에 담보권의 실행에 의한 압류가 이루어진 사실 및 명령 송달의 일시 등이 기재된다.

9) 근질권의 목적이 된 금전채권에 대하여 근질권자가 아닌 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우, 제3채무자가 그 절차의 전부명령이나 추심명령에 따라 전부금 또는 추심금을 제3자에게 지급하거나 채권자의 경합 등을 사유로 위 금전채권의 채권액을 법원에 공탁하게 되면 그 변제의 효과로서 위 금전채권은 소멸하고 그 결과 바로 또는 그 후의 절차진행에 따라 종국적으로 근질권도 소멸하게 되므로 근질권이 설정된 금전채권에 대하여 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우 근질권의 피담보채권은 근질권자가 위와 같은 강제집행이 개시된 사실을 알게 된 때에 확정된다고 봄이 타당하다.⁷¹⁰⁾

나. 불복방법 등

채권 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행에 관하여는 부동산경매에 관한 민사집행법 제264조 내지 제267조의 규정이 준용되므로(민집규 제200조), 담보권실행에 대한 불복절차 즉 압류명령이나 추심명령, 전부명령 등에 대한 즉시항고절차에서는 일반 강제집행의 경우와 달리 담보권이나 피담보채권의 소멸, 부존재, 변제기미도래 등 실체에 관한 사유도 불복사유로 주장할 수 있다(민집 제265조).

또 담보권실행의 일시정지를 명한 재판의 정본, 담보권이 없거나 소멸되었다는 취지의 확정판결의 정본 등 민사집행법 제266조의 서류가 제출된 때에는 담보권실행 절차를 정지 또는 취소하여야 하고(민집 제266조), 법원사무관등은 그 사실을 예탁결제원 또는 예탁자에게 통지하여야 한다(민집규 제160조, 제161조).

그러나 담보권실행을 위한 현금화절차가 종료한 때에는 그로 인한 권리이전의 효과는 담보권의 소멸로 영향을 받지 않는다(민집 제267조).

710) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다43621 판결

III. 물상대위

1. 의의

가. 담보목적물의 멸실·훼손 또는 공용징수로 저당권을 사실상 또는 법률상 행사할 수 없게 된 경우에 그로 인하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건이 있으면 그 금전 기타 물건(저당목적물의 가치변형물)에 대하여 저당권의 효력이 미치는 것을 저당권의 물상대위라 한다. 이는 담보물권이 목적물의 실체를 목적으로 하는 권리가 아니라 주로 그 교환가치를 취득하는 것을 목적으로 하는 권리이므로 비록 그 목적물이 멸실 또는 훼손되더라도 그 교환가치를 대표하는 것이 그대로 존재하는 때에는 담보물권은 다시 이 가치의 대표물 위에 존속하는 것으로 하는 것이 담보물권의 본질에 적합하기 때문에 인정되는 것이다.

나. 민법 그 밖에 특별법(민법 제342조, 제355조, 제370조, 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제47조)에 담보권의 내용으로서 질권·저당권 등의 담보권의 목적물이 멸실, 훼손, 공용징수로 인하여 담보권설정자가 받게 될 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다는 규정을 둔 경우 즉 담보권자의 물상대위권이 인정되는 경우 그 행사에 있어서도 권리질권 실행의 방법이 그대로 적용된다(민집 제273조). 그러나 직접 추심에 관한 민법 제353조는 그 적용이 없다. 토지수용의 경우 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제47조는 ‘담보물권의 목적물이 수용 또는 사용된 경우 당해 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다. 다만 그 지급 전에 이를 압류하여야 한다’고 규정되어 있다. 따라서 사업시행자가 근저당권이 설정된 토지를 수용하고 토지소유자를 공탁물을 수령할 자로 하여 보상금을 공탁한 경우 근저당권자는 토지의 변형물인 공탁금이 특정성을 유지하는 한 물상대위권을 행사하여 우선변제를 받을 수가 있다.⁷¹¹⁾ 그러나 저당권자가 위 금전 또는 물건의 인도청구권을 압류하기 전에 저당물

711) 양도담보로 제공된 목적물이 멸실, 훼손됨에 따라 양도담보 설정자와 제3자 사이에 교환가치에 대한 배상 또는 보상 등의 법률관계가 발생하는 경우에도 그로 인하여 양도담보 설정자가 받을 금전 기타 물건에 대하여 담보적 효력이 미치므로 양도담보권자는 양도담보 목적물이 소실되어 양도담보 설정자가 보험회사에 대하여 화재보험계약에 따른 보험금청구권을 취득한 경우에도 담보물 가치의 변형물인 위 화재보험금청구권에 대하여 양도담보권에 기한 물상대위권을 행사할 수 있다는 판결로는 대법원 2009. 11. 26. 선고 2006다37106 판결 참조.

의 소유자가 그 인도청구권에 기하여 금전 등을 수령한 경우 저당목적물 소유자는 저당권자에게 이를 부당이득으로 반환할 의무가 있다.⁷¹²⁾

여기서 금전 기타 물건 즉 대상물(代償物)에 해당하는 것으로서는 목적물의 멸실, 훼손으로 인한 손해배상금, 토지수용의 손실보상금(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제61조, 광업법 제73조), 도시개발법에 의한 청산금(도시개발법 제41조)과 보험금 등을 생각할 수 있다. 또 질물의 부합, 혼화, 가공으로 인한 보상금(민법 제261조)도 이에 해당한다. 그러나 담보권자가 목적물에 추급할 수 있는 경우 예컨대 매매 또는 임대의 경우에는 그 매각대금 또는 차임에 대하여 물상대위가 인정되지 아니한다.⁷¹³⁾

다. 전세권저당권자(甲)가 전세금반환채권에 대하여 물상대위권을 행사한 경우, 종전 저당권의 효력은 물상대위의 목적이 된 전세금반환채권에 존속하여 저당권자가 그 전세금반환채권으로부터 다른 일반채권자보다 우선변제를 받을 권리가 있으므로, 설령 전세금반환채권이 압류된 때에 전세권설정자(丙)가 전세권자(乙)에 대하여 반대채권을 가지고 있고 그 반대채권과 전세금반환채권이 상계적상에 있다고 하더라도 그 사정만으로 전세권설정자가 전세권저당권자에게 상계로써 대항할 수는 없다. 그러나 전세금반환채권은 전세권이 성립하였을 때부터 이미 그 발생이 예정되어 있으므로, 전세권저당권이 설정된 때에 이미 전세권설정자가 전세권자에 대하여 반대채권을 가지고 있고 그 반대채권의 변제기가 장래 발생할 전세금반환채권의 변제기와 동시에 또는 그보다 먼저 도래하는 경우와 같이 전세권설정자에게 합리적 기대이익을 인정할 수 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 전세권설정자는 그 반대채권을 자동채권으로 하여 전세금반환채권과 상계함으로써 전세권저당권자에게 대항할 수 있다.⁷¹⁴⁾

라. 동산 양도담보권자는 양도담보 목적물이 소실되어 양도담보 설정자가 보험회사에 대하여 화재보험계약에 따른 보험금청구권을 취득한 경우 담보물가치의 변형물인 화재보험금청구권에 대하여 양도담보권에 기한 물상대위권을 행사할 수 있다.⁷¹⁵⁾ 동산채권담보법에 따른 동산담보권자도 담보목적물의 매각, 임대, 멸실, 훼손 또는 공용징수 등으로 인하여 담보권설정자가 받을 금전이나 그 밖의 물건에 대하여도 물

712) 대법원 2009. 5. 14. 선고 2008다17656 판결

713) 다만 차임에 대하여는 반대하는 견해가 있다.

714) 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결

715) 대법원 2014. 9. 25. 선고 2012다58609 판결

상대위를 할 수 있는데(같은 법 제14조), 그 절차는 채권집행의 방식을 따르므로(같은 법 제36조 제3항, 민집 제273조), 이에 대하여는 아래 IV. 채권담보권의 실행 부분에서 설명하기로 한다.

2. 권리의 실행방법

가. 물상대위권을 행사하는 방법은 민사집행법 제273조에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하거나 민사집행법 제274조 제1항에 의하여 그 배당요구 종기까지 배당요구를 하는 것이다.⁷¹⁶⁾ 따라서 일반 채권자로서 강제집행을 하는 것이 아니므로 집행권원을 필요로 하지 않는다

나. 물상대위권을 행사하기 위해서는 대상물인 금전 그 밖의 물건의 지급 또는 인도청구권을 그 지급 전에 압류하여야 한다(민법 제370조, 제342조, 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제47조).

압류의 목적이 금전지급청구권인 경우에는 금전채권의 압류에 관한 방법으로, 물건인도청구권인 경우에는 유체물인도청구권의 압류와 유체물인도명령에 관한 방법으로 압류한다. 압류명령신청서에는 담보권의 존재를 증명하는 서류를 붙여야 한다. 그러나 목적물의 멸실 등으로 금전 그 밖의 물건으로 전환되었다는 증명은 필요 없다.

위와 같이 압류를 필요로 하는 이유는 압류를 통하여 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하도록 함으로써 그 효력을 보전함과 동시에 평등배당을 기대한 다른 일반 채권자의 신뢰를 보호하는 등 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 것이고,⁷¹⁷⁾ 만약 담보권설정자에게 지급된 후에도 물상대위권을 인정하면 일반재산 위에 우선권을 인정하는 결과가 되어 물상대위권을 인정하는 제도의 취지에 반하기 때문이다.

다. 압류는 반드시 근저당권자 스스로 하여야 하는 것은 아니고, 이미 제3자가

716) 대법원 2003. 3. 28. 선고 2002다13539 판결. 따라서 저당권자의 물상대위권 행사로서의 압류 및 전부는 그 명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 효력이 생기며, 물상대위권의 행사를 제한하는 취지인 '특정성의 유지'나 '제3자의 보호'는 물상대위권자의 압류 및 전부명령이 효력을 발생함으로써 비로소 달성될 수 있는 것이므로, 배당요구의 종기가 지난 후에 물상대위에 기한 채권 압류 및 전부명령이 제3채무자에게 송달되었을 경우에는, 물상대위권자는 배당절차에서 우선변제를 받을 수 없다.

717) 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결; 그 외에 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다25728 판결; 대법원 1999. 5. 14. 선고 98다62688 판결; 대법원 2000. 5. 12. 선고 2000다4272 판결; 대법원 2000. 6. 23. 선고 98다31899 판결; 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33137 판결; 대법원 2003. 3. 28. 선고 2002다13539 판결 등

압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자는 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사할 수 있다.⁷¹⁸⁾ 이 경우 물상대위권의 행사방법은 민사집행법 제273조에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사집행법 제274조 제1항에 의하여 배당요구를 하는 것이다. 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없고, 저당권자가 물상대위권의 행사에 나아가지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 그 보상금 또는 이에 관한 변제공탁금으로부터 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수도 없다.⁷¹⁹⁾

718) 대법원 1996. 7. 12. 선고 96다21058 판결【판결요지】[1] 민법 제370조에 의하여 저당권에 준용되는 제342조 후문이 “저당권자가 물상대위권을 행사하기 위하여서는 저당권 설정자가 지급 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.”라고 규정한 취지는, 물상대위의 목적이 되는 금전 기타 물건의 특정성을 유지하여 제3자에게 불측의 손해를 입히지 아니하려는 데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자는 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사할 수 있다. [2] 국세에 대하여 우선적으로 보호되는 저당권으로 담보되는 채권이라 함은 원래 저당권 설정 당시의 저당권자와 저당권설정자와의 관계를 기본으로 하여 그 설정자의 납세의무를 기준으로 한 것이라고 해석되므로 저당권설정자가 그 피담보채권에 우선하여 징수당할 아무런 조세의 체납도 없는 상태에서 사망한 경우에 그 상속인에 대하여 부과한 국세인 상속세는 이를 당해세라 하여 우선 징수할 수 없고, 이러한 법리는 저당권의 목적인 재산 그 자체를 매각한 대금 중에서 국세를 징수하는 경우뿐만 아니라 그 재산이 수용되어 그 수용보상금이 공탁된 관계로 그 공탁금이 물상대위의 대상이 된 경우에도 동일하게 적용된다.

719) 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다25728 판결; 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결; 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33137 판결【판결요지】민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사집행법 제273조[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조]에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사집행법 제247조 제1항[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제580조 제1항]에 의하여 배당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없고, 저당권자가 물상대위권의 행사에 나아가지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 그 보상금 또는 이에 관한 변제공탁금으로부터 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수 없다.; 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다46756 판결【판결요지】물상대위권자로서의 권리행사 방법과 시한을 제한하는 취지가 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전하고 제3자에게 불측의 손해를 입히지 아니하려는 데에 있는 점 등을 고려하면, 저당권에 의하여 담보된 채권이었으나 그 저당목적물의 변형물인 금전에 대하여 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 이상, 그 채권을 국세징수법 제81조 제1항 제3호에 규정된 ‘압류재산에 관계되는 저당권에 의하여 담보된 채권’으로 볼 수는 없다.

또한 전세권에 대한 저당권자는 전세권의 존속기간이 만료하면 민법 제370조, 제342조, 민사집행법 제273조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 추심명령 또는 전부명령을 받거나 제3자가 전세금반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사할 수 있고, 적법한 기간 내에 적법한 방법으로 물상대위권을 행사한 저당권자는 전세권자에 대한 일반채권자보다 우선변제를 받을 수 있다.⁷²⁰⁾

라. 저당권에 기한 물상대위권을 갖는 채권자가 동시에 집행권원을 가지고 있으면서 집행권원에 의한 강제집행의 방법을 선택하여 채권의 압류 및 전부명령을 얻은 경우에는 비록 그가 물상대위권을 갖는 실체법상의 우선권자라 하더라도 원래 일반 집행권원에 의한 강제집행절차와 담보권의 실행절차와는 그 개시요건이 다를 뿐만 아니라 다수의 이해관계인이 관여하는 집행절차의 안정과 평등배당을 기대한 다른 일반 채권자의 신뢰를 보호할 필요가 있는 점에 비추어 압류가 경합된 상태에서 발부된 전부명령은 무효로 볼 수밖에 없다.⁷²¹⁾

그리고 근저당권자가 물상대위권 행사를 위한 압류를 하지 아니하고 일반채권에 기하여 가압류만 하고 있던 중에 다른 채권자가 압류를 하게 되면 공탁관은 압류와 가압류의 경합을 사유로 하여 압류법원에 사유신고를 하게 되므로 그 이후에는 근저당권자는 물상대위권 행사를 위한 압류나 배당요구를 할 수 없게 되어(사유신고로 인한 배당가입차단효로 인하여) 근저당권자는 위 배당절차에서 근저당권자가 아닌 단순

720) 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006다29372, 29389 판결

721) 대법원 1990. 12. 26. 선고 90다카24816 판결【판결요지】[1] 청산금 징수 교부의 대상은 원칙적으로 환지처분 공고 당시의 등기부상의 토지소유자 즉 환지된 토지의 소유자라 하겠지만 토지구획정리사업법 제79조 제1항에 의하면 시행지구 안의 토지 등에 관하여 권리를 가진 자에 변동이 있는 때에는 당해 권리자 등은 대통령령이 정하는 바에 의하여 그 사유를 사업시행자에게 신고하여야 함에도 불구하고 환지처분공고일 직전에 매매에 의하여 소유자가 변동됨으로써 시행자인 시로서는 이를 알 수도 없었던 상황인데도 종전 토지소유자와 그 매수인이 이를 신고하지 않았다면 시가 환지처분의 일환으로서 종전의 소유자에게 청산금교부처분을 한 것은 적법 유효하고, 따라서 시에 대한 청산금교부청구권은 같은 법 제62조 제5항에 의하여 위 환지처분의 공고가 있는 날의 익일부터 종전의 소유자에게 귀속되는 것으로 확정되었다 할 것이다. [2] 토지구획정리사업법에 의한 환지청산금은 제52조 제2항에 의하여 원칙적으로 환지처분시 결정되어야 하나 제46조 제2항 제3호는 환지계획에서 청산대상토지명세를 정하도록 하여 이 단계에서는 그 청산금채권의 기초와 내용이 어느 정도 구체화되므로 이러한 미확정의 청산금채권도 압류의 목적이 될 수 있는 것이므로 환지처분공고 전의 위 단계에서 이루어진 압류도 유효하다. [3] 저당권에 기한 물상대위권을 갖는 채권자가 동시에 채무명의를 가지고 있으면서 채무명예에 의한 강제집행의 방법을 선택하여 채권의 압류 및 전부명령을 얻은 경우에는 비록 그가 물상대위권을 갖는 실체법상의 우선권자라 하더라도 원래 일반 채무명예에 의한 강제집행절차와 담보권의 실행절차와는 그 개시요건이 다를 뿐만 아니라 다수의 이해관계인이 관여하는 집행절차의 안정과 평등배당을 기대한 다른 일반 채권자의 신뢰를 보호할 필요가 있는 점에 비추어 압류가 경합된 상태에서 발부된 전부명령은 무효로 볼 수 밖에 없다.

한 가압류채권자로서 다른 채권자들과 안분배분을 받을 수 있을 뿐이다.⁷²²⁾

마. 대상물이 금전인 경우에는 금전채권에 대한 집행에 있어서와 마찬가지로 추심명령, 전부명령 또는 특별현금화명령에 의하여 현금화한다.

대상물이 물건인 때에는 유체물인도청구권에 대한 집행에 있어서와 마찬가지로 추심명령을 얻어 또는 그 후 추심의 소를 통하여 집행관으로 하여금 물건을 인도받게 한 다음에 유체동산집행에 관한 방법으로 현금화한다(민집 제243조).

바. 동산양도담보권자가 물상대위권 행사로 양도담보 설정자의 화재보험금청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 얻어 추심권을 행사하는 경우 제3채무자인 보험회사가 그 양도담보 설정 후 취득한 양도담보 설정자에 대한 별개의 채권을 가지고 상계로써 양도담보권자에게 대항할 수 없고, 이는 보험금청구권과 그 본질이 동일한 공제금청구권에 대하여 물상대위권을 행사하는 경우에도 마찬가지이다.⁷²³⁾

722) 1992. 11. 19. 법정제2002호 “피수용토지의 소유자가 받을 보상금에 대하여 담보물권자가 물상대위권을 행사하는 방법과 그 행사 시기”(공탁선례 1-232) : 근저당권자 ‘갑’이 근저당권설정자 ‘을’이 받을 토지수용보상의 공탁금에 대하여 물상대위권을 행사하려면 그 지불 전에 이를 압류하여야 하고(토지수용법 제69조 단서), 공탁금출급청구권에 대하여 가압류의 경합만이 있는 상태에서는 공탁공무원의 사유신고에 기한 배당절차가 개시될 수는 없는 것이며, ‘갑’이 위 공탁금에 대하여 물상대위권을 행사하기 위하여 근저당권의 존재를 증명하는 서류(등기부등본)를 제출하여 채권에 대한 강제집행절차에 준하는 채권압류 및 전부명령을 받은 경우에는 그 공탁금에 대하여 다른 일반 채권자가 먼저 가압류나 압류의 집행을 하였다 하더라도 그에 우선하여 변제를 받을 수 있을 것이나(대법원 1992.12.26. 선고, 90다카24816 판결), ‘갑’이 위 공탁금에 대하여 물상대위권 행사를 위한 압류를 하지 아니하고 일반채권에 기하여 가압류만 하고 있던 중에 다른 채권자가 압류를 하게 되면 공탁공무원은 압류와 가압류의 경합을 사유로 하여 압류법원에 사유신고를 하게 된다(공탁규칙 제58조). 따라서 그 이후에는 ‘갑’은 물상대위권 행사를 위한 압류나 배당요구를 할 수 없으므로(민소 제580조 참조), ‘갑’은 위 배당절차에서 근저당권자가 아닌 단순한 가압류채권자로서 다른 채권자들과 안분배분을 받을 수 있을 뿐이며, 이 경우 ‘갑’이 다른 집행법원으로부터 근저당권의 피보전채권의 잔존채권에 대한 부기문을 받았다 하더라도 그 부기문 자체로서는 집행력이 없고, 단지 부동산임의경매절차에서 지급받은 배당액을 입증하는 것에 불과하다고 보아야 할 것이다.

질의요지 : 근저당권설정자 ‘을’의 토지가 기업자에 의하여 수용되고 그 보상금이 ‘을’을 피공탁자로 하여 공탁된 경우 ‘을’이 받을 공탁금을 근저당권자 ‘갑’이 물상대위권 행사가 아닌 일반채권에 기하여 가압류하고 그 후 다른 채권자 ‘병’이 위 공탁금을 가압류한 경우에 근저당권자 ‘갑’이 다른 채권자 ‘병’보다 우선하여 근저당권상의 피담보채권을 변제받을 수 있는지 여부와 그 절차, 만약 가압류의 경합으로 배당절차가 개시된다면 ‘갑’이 다른 집행법원에서 부여받은 부기문에 기재된 잔존채권으로 배당받을 수 있는지의 여부

723) 대법원 2014. 9. 25. 선고 2012다58609 판결(양도담보권자인 원고가 양도담보대상인 양계장의 가금류가 화재로 폐사한 직후 양도담보설정자의 피고에 대한 가축공제계약에 기한 공제금청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 얻어 추심권을 행사하자 제3채무자인 피고가 위 양도담보 설정 후 취득한 양도담보 설정자에 대한 별개의 채권을 가지고 상계를 주장하는 사건에서 제3채무자인 피고가 양도담보권자인 원고에게 대하여 위 상계로 대항할 수 없다고 판단한 원심이 타당하다고 보아 상고를 기각한 사안)

3. 토지수용의 경우 물상대위권의 행사

가. 토지수용의 경우 사업인정의 고시가 있으면 수용대상토지에 대한 손실보상금의 지급이 확실시되므로 토지수용의 재결 이전 단계에서도 물상대위권을 행사할 수 있다.⁷²⁴⁾ 수용보상금이 공탁되기 이전에는 보상금지급청구권에 대하여 제3채무자를 사업시행자로, 공탁한 이후에는 공탁금출급청구권에 대하여 제3채무자를 국가(공탁관)로 하여 압류하여야 할 것이다.

724) 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결【판결요지】[1] 토지수용법 제61조 제2항에 의한 수용보상금의 공탁에 있어서는 기업자가 공탁물을 회수하면 공탁이 없었던 것이 되어 재결이 효력을 상실하므로 기업자가 토지수용의 재결이 있는 후 토지보상금을 공탁하였다면 그 수용재결이 당연무효이거나 소송 등에 의하여 취소되지 않는 한 기업자는 민법에 의한 공탁과는 달리 그 공탁금에 대한 회수청구를 할 수 없다. [2] 공탁이 수리된 후 공탁물수령자에 대한 사항에 착오가 있음이 발견된 경우라고 할지라도 그것이 표현상의 착오임이 명백하고 또한 공탁의 동일성에 영향을 미치지 아니하는 범위 내에서만 공탁서의 정정이 가능할 뿐이므로 공탁물수령자를 추가하는 공탁서 정정은 공탁의 동일성을 해하는 것으로서 허용될 수 없다. [3] 민법 제370조, 제342조 단서가 저장권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저장권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로 저장목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저장권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사소송법 제733조에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사소송법 제580조 제1항에 의하여 배당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없다. [4] 토지수용법 제61조 제2항 제4호의 규정에 따라 압류 또는 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었음을 이유로 공탁하는 경우에는 공탁원인 사실에 압류 또는 가압류의 내용을 구체적으로 명시하여야 하고, 이 경우 공탁을 수리한 공탁공무원은 원표에 공탁금출급청구권에 대한 압류·가압류사실을 기재하고 공탁금출급청구권에 대한 압류·가압류가 있는 경우에 준하여 처리하여야 하며, 보상금지급청구권에 대한 중복압류(가압류를 포함한다)에 의하여 채권자가 경합된 경우에는 토지수용법 제61조 제2항 제4호 및 민사소송법 제581조에 의하여 기업자는 그 보상금을 집행공탁을 함으로써 면책될 수 있다. [5] 담보권자는 토지수용법 제14조, 제16조 소정의 사업인정의 고시가 있으면 수용대상토지에 대한 손실보상금의 지급이 확실시되므로 토지수용의 재결 이전 단계에서도 물상대위권의 행사로서 피수용자의 기업자에 대한 손실보상금 채권을 압류 및 전부받을 수 있어, 설사 그 압류 전에 양도 또는 전부명령 등에 의하여 보상금 채권이 타인에게 이전된 경우라도 보상금이 직접 지급되거나 보상금지급청구권에 관한 강제집행절차에 있어서 배당요구의 종기에 이르기 전에는 여전히 그 청구권에 대한 추급이 가능하다. [6] 기업자가 보상금지급에 관한 사무처리지침을 정하고 그 내용을 담보권자에게 통지함으로써 그에 대한 담보권자의 신뢰가 형성되었음에도 후에 기업자 소속 담당공무원이 고의 또는 과실로 그 통지된 사무처리지침과 달리 보상금지급업무를 처리하여 담보권자로부터 물상대위권을 행사할 수 있는 기회를 박탈하여 결과적으로 담보권자로 하여금 우선변제권을 상실하게 하였다면 이는 공무원의 직무상 불법행위로 국가배상책임이 성립할 수 있다.

나. 담보물권의 목적물이 수용되었을 경우에 보상금에 대하여 당해 담보물권을 행사하기 위한 요건으로서 그 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.⁷²⁵⁾ 지급 전에 압류를 요하는 취지는, 앞서 본 바와 같이 보상금이 소유자의 일반재산에 혼입되기 전까지, 즉 물상대위의 목적이 되는 보상금의 특정성을 유지하여 제3자에게 불측의 손해를 입히지 아니하려는 데 있는 것이므로 사업시행자가 보상금을 변제공탁하였다고 하더라도 이 공탁금이 출급되기까지는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제47조 단서가 규정하는 지불이 있었다고 할 수 없다. 이는 보상금의 변제의 효과와는 별개의 문제이다.⁷²⁶⁾ 따라서 설사 그 압류 전에 양도 또는 전부명령 등에 의하여 보상금 채권이 타인에게 이전된 경우라도 보상금이 직접 지급되거나 보상금지급청구권에 관한 강제집행절차에 있어서 배당요구의 종기에 이르기 전에는 여전히 그 청구권에 대한 추급이 가능하다.⁷²⁷⁾

725) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2013다216273 판결

726) 대법원 1992. 7. 10.자 92마380, 381 결정【결정요지】[1] 근저당권에 기한 물상대위권을 갖는 채권자가 그 물상대위권을 행사하여 우선변제를 받음에 있어, 그 권리실행방법은 민사소송법 제733조에 의하여 채권에 대한 강제집행절차를 준용하여 채권의 압류 및 전부명령을 신청할 수 있다고 할 것이나, 이는 어디까지나 담보권의 실행절차이므로 그 요건으로서 담보권의 존재를 증명하는 서류를 제출하여 개시하면 되는 것이고, 일반채권자로서 강제집행을 하는 것이 아니므로 채무명의를 필요로 하지 않는다. [2] 토지수용법 제69조가 담보물권의 목적물이 수용되었을 경우 보상금에 대하여 당해 담보물권을 행사하기 위한 요건으로서 그 지불 전에 압류할 것을 요구하는 이유는, 보상금이 소유자의 일반재산에 혼입되기 전까지, 즉 특정성이 유지 보전되고 있는 한도 안에서 우선변제권을 인정하고자 함에 있다. [3] 토지수용에 있어 기업자가 보상금을 변제공탁하였다고 하더라도 이 공탁금이 출급되어 수용 대상 부동산 소유자의 일반재산에 혼입되기까지도 지수용법 제69조 단서가 규정하는 지불이 있었다고 할 수 없고, 이는 보상금의 변제의 효과와는 별개의 문제라고 할 것이다.

727) 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결【판결요지】[1] 토지수용법 제61조 제2항에 의한 수용보상금의 공탁에 있어서는 기업자가 공탁물을 회수하면 공탁이 없었던 것이 되어 재결이 효력을 상실하므로 기업자가 토지수용의 재결이 있은 후 토지보상금을 공탁하였다면 그 수용재결이 당연 무효이거나 소송 등에 의하여 취소되지 않는 한 기업자는 민법에 의한 공탁과는 달리 그 공탁금에 대한 회수청구를 할 수 없다. [2] 공탁이 수리된 후 공탁물수령자에 대한 사항에 착오가 있음이 발견된 경우라고 할지라도 그것이 표현상의 착오임이 명백하고 또한 공탁의 동일성에 영향을 미치지 아니하는 범위 내에서만 공탁서의 정정이 가능할 뿐이므로 공탁물수령자를 추가하는 공탁서 정정은 공탁의 동일성을 해하는 것으로서 허용될 수 없다. [3] 민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사소송법 제733조에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사소송법 제580조 제1항에 의하여 배

그러나 보상금에 대하여 다른 일반 채권자가 먼저 가압류나 압류의 집행을 하였고 하더라도 담보물권자는 물상대위권을 행사하여 우선변제를 받을 수 있지만 일단 사업시행자가 공탁하고 공탁사유신고를 한 때 또는 추심채권자가 추심하고 추심신고를 한 때에는 배당요구의 종기가 지난 후이므로 물상대위권을 행사할 수 없다.⁷²⁸⁾ 또한 근저당권자가 금전이나 물건의 인도청구권을 압류하기 전에 토지의 소유자가 인도청구권에 기하여 금전 등을 수령한 경우 근저당권자는 더 이상 물상대위권을 행사할 수 없다.⁷²⁹⁾

다. 공탁실무상 물상대위권의 행사와 관련하여 문제되는 것은 사업시행자가 공탁 이후 민사집행법 제248조 제4항에 의하여 공탁사유신고를 한 경우에 저당권자가 물상대위권을 행사할 수 있는지 여부에 관한 것이다.

이에 관하여 물상대위권은 늦어도 민사집행법 제247조 제1항 각 호에서 정하고 있는 배당요구의 종기까지 하여야 하므로 저당권자로서는 제3채무자가 민사집행법 제248조 제4항 소정의 공탁사유신고를 하기 이전에 스스로 담보권의 존재를 증명하는 서류를 제출하여 물상대위권의 목적채권을 압류하거나 법원에 배당요구를 하여야 하

당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없다. [4] 토지수용법 제61조 제2항 제4호의 규정에 따라 압류 또는 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었음을 이유로 공탁하는 경우에는 공탁원인 사실에 압류 또는 가압류의 내용을 구체적으로 명시하여야 하고, 이 경우 공탁을 수리한 공탁공무원은 원표에 공탁금출급청구권에 대한 압류·가압류사실을 기재하고 공탁금출급청구권에 대한 압류·가압류가 있는 경우에 준하여 처리하여야 하며, 보상금지급청구권에 대한 중복압류(가압류를 포함한다)에 의하여 채권자가 경합된 경우에는 토지수용법 제61조 제2항 제4호 및 민사소송법 제581조에 의하여 기업자는 그 보상금을 집행공탁을 함으로써 면책될 수 있다. [5] 담보권자는 토지수용법 제14조, 제16조 소정의 사업인정의 고시가 있으면 수용대상토지에 대한 손실보상금의 지급이 확실시되므로 토지수용의 재결 이전 단계에서도 물상대위권의 행사로서 피수용자의 기업자에 대한 손실보상금 채권을 압류 및 전부받을 수 있어, 설사 그 압류 전에 양도 또는 전부명령 등에 의하여 보상금 채권이 타인에게 이전된 경우라도 보상금이 직접 지급되거나 보상금지급청구권에 관한 강제집행절차에 있어서 배당요구의 종기에 이르기 전에는 여전히 그 청구권에 대한 추급이 가능하다. [6] 기업자가 보상금지급에 관한 사무처리지침을 정하고 그 내용을 담보권자에게 통지함으로써 그에 대한 담보권자의 신뢰가 형성되었음에도 후에 기업자 소속 담당공무원이 고의 또는 과실로 그 통지된 사무처리지침과 달리 보상금지급업무를 처리하여 담보권자로부터 물상대위권을 행사할 수 있는 기회를 박탈하여 결과적으로 담보권자로 하여금 우선변제권을 상실하게 하였다면 이는 공무원의 직무상 불법행위로 국가배상책임이 성립할 수 있다.

728) 1992. 11. 19. 법정 제2002호 “피수용토지의 소유자가 받을 보상금에 대하여 담보물권자가 물상대위권을 행사하는 방법과 그 행사 시기”(공탁선례 1-232)

729) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2013다216273 판결

는 것이고, 그 이후에는 물상대위권자로서의 우선변제권을 행사할 수 없게 된다.⁷³⁰⁾ 민사집행법 제247조 제1항이 압류채권자 이외의 채권자가 배당요구의 방법으로 채권에 대한 강제집행절차에 참가하여 압류채권자와 평등하게 자신의 채권의 변제를 받는 것을 허용하면서도, 다른 한편으로 그 배당요구의 종기를 제3채무자의 공탁사유 신고 시까지로 제한하고 있는 이유는, 제3채무자가 채무액을 공탁하고 그 사유 신고를 마치면 배당할 금액이 판명되어 배당절차를 개시할 수 있는 만큼 늦어도 그 때까지는 배당요구가 마쳐져야 배당절차의 혼란과 지연을 막을 수 있다고 본 때문이고, 이러한 배당요구 시한의 설정은 배당요구를 제한 없이 허용할 경우에 초래될 배당절차의 혼란과 지연을 방지하기 위한 합리적인 조치로서, 물상대위에 있어서 우선변제청구권 있는 자의 경우라 하여 달리 취급할 수 없기 때문이다.⁷³¹⁾ 따라서 제3채무자의 공탁사유신고가 있게 되면 배당가입차단효로 인하여 더 이상 물상대위권 행사는 할 수 없게 된다.

라. 공동담보 목적물 중 일부의 수용보상금에 대한 배당절차에 참가하여 채권최고액 전액을 배당받은 근저당권자가 다른 공동담보 목적물에 대한 경매절차에서 다시 우선변제권을 행사할 수 있는지가 문제로 될 수 있으나, 이에 대하여 우리 대법원 2006. 10. 27. 선고 2005다14502 판결은, “근저당권자로서 우선변제권을 행사하기 위해서는 근저당권의 피담보채권이 확정될 것이 요구될 뿐 그 본체적 효력으로서의 우선변제권은 저당권과 다를 바가 없고, 이 경우 근저당권의 우선변제권은 채권최고액을 한도로 일반채권자 또는 후순위의 담보권자보다 우선하여 변제를 받는 것이며,

730) 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33137 판결【판결요지】민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는 데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사집행법 제273조[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제733조]에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사집행법 제247조 제1항[구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제580조 제1항]에 의하여 배당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없고, 저당권자가 물상대위권의 행사에 나아가지 아니하여 우선변제권을 상실한 이상 다른 채권자가 그 보상금 또는 이에 관한 변제공탁금으로부터 이득을 얻었다고 하더라도 저당권자는 이를 부당이득으로서 반환청구할 수 없다.

731) 대법원 1999. 5. 14. 선고 98다62688 판결

이는 공동근저당권의 경우에도 마찬가지여서 공동근저당권의 우선변제권은 그 목적물의 전체 환가대금에서 위와 같은 우선변제권 범위의 채권을 우선하여 변제받을 수 있는 권리이다. 비록 공동담보의 목적 부동산 중 일부 부동산이 수용됨에 따라 근저당권자가 물상대위의 법리에 의하여 불가피하게 그 수용보상금에 대한 배당절차에 참가함으로써 배당을 받게 되었다고 하더라도, 그 배당절차에서 자신의 우선변제권을 행사하여 우선변제권 범위의 채권최고액에 해당하는 전액을 배당받은 근저당권자로서는 공동담보 목적 부동산 중 다른 부동산에 대한 임의경매절차에서 다시 반복하여 공동근저당권자로서 우선변제권의 행사를 주장할 수는 없다.”라고 판시하여 이를 소극적으로 보고 있다. 타당하다고 생각한다.

마. 근저당권의 채무자가 아닌 제3취득자 또는 물상보증인이 소유자로 등기되어 있는 토지가 수용된 경우, 그 수용으로 인한 손실보상금지급청구권은 부동산의 소유자에게 있으므로 그 소유자(제3취득자 또는 물상보증인)를 물상대위를 위한 압류명령의 채무자로 기재하여야 한다.⁷³²⁾ 채권집행인 압류명령의 기본구조는 채권자, 채무자 및 제3채무자이고, 물상대위에 의한 압류명령은 부동산의 소유자가 기업자에 대하여 가지게 될 보상금지급채권을 압류하는 구조이며, 이와 같이 압류할 수 있는 근거는 채권자가 물상보증인인 부동산소유자가 가지는 부동산에 대하여 저당권을 설정하였기 때문이다.⁷³³⁾

또한 이 경우에는 신청서에 소유자가 채무자로 표시될 것이므로 압류사건의 관할도 소유자의 주소지가 그 기준이 된다.

4. 다른 채권자와의 관계

가. 저당권 등에는 우선변제권이 있으므로 저당권자가 물상대위권에 기하여 채권을 압류한 경우에는 그 동일한 채권에 대하여 압류의 경합이나 배당요구가 있는 때에도 저당권자를 위하여 전부명령이나 양도명령을 얻어 우선변제받을 수 있다.

이는 위 물상대위권에 기한 압류가 다른 채권자에 의한 압류나 배당요구의 뒤에 이루어진 경우에도 마찬가지이다.⁷³⁴⁾ 즉 가압류·압류·추심·전부 채권자는 비록 물상대위권

732) 민사집행규칙 제192조는 신청서에 채권자, 채무자 소유자를 적도록 규정하고 있으나, 그것이 모든 경우에 있어서 채권자, 채무자, 소유자를 반드시 표시해야 한다는 취지의 규정은 아니다.

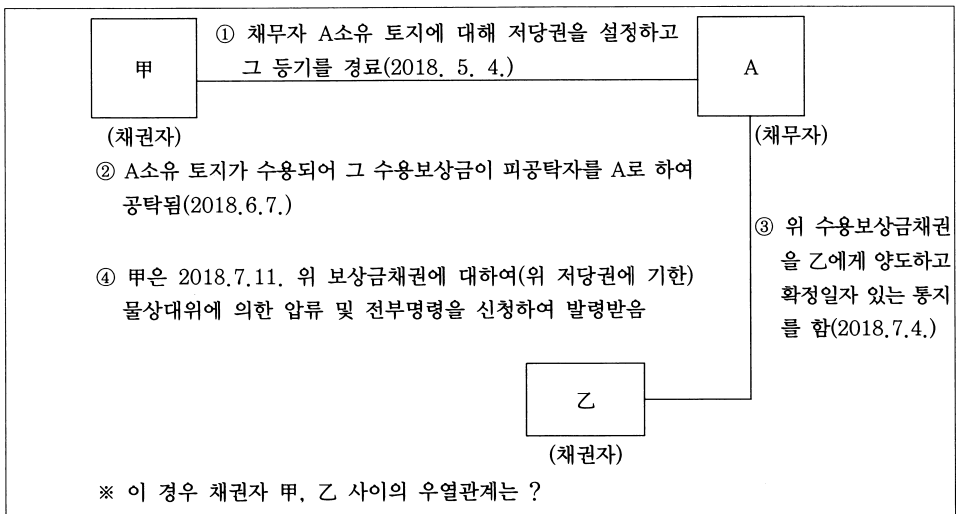
733) 즉 위 부동산 자체를 집행할 때에 있어서는 물상보증인인 소유자는 단지 소유자이고 그와 다른 채무자가 존재하게 되는 것이나, 위 저당권에 기한 물상대위에 의해 소유자가 지급받을 보상금채권을 압류하게 되는 채권집행에 있어서는 위 부동산의 소유자가 채무자의 지위에 서게 된다고 볼 수 있다.

734) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 489-490.

행사 전에 이미 가압류·압류·추심·전부 명령을 얻었다고 하더라도 보상금이 직접 지급되거나 배당요구의 종기에 이르기 전에는 담보권자가 물상대위권을 행사하면 그 물상대위권자가 다른 일반 채권자에 우선하여 보상금 지급을 받거나 공탁된 보상금을 출급할 수 있다.

나. 토지수용의 경우에도, 담보권자의 담보 목적물의 수용보상금청구권에 대한 물상대위권은 이를 행사하기 위하여 그 대위물을 압류하여야 하는 것과는 별개로, 그 자체는 담보 목적물이 수용됨과 동시에 당연히 발생하여 그 대위물에 효력을 미치는 것이므로 비록 일반채권자가 담보권자보다 먼저 그 보상금청구권에 대하여 압류 및 전부명령을 받았다 하더라도, 이는 타인의 우선권의 목적이 되는 채권 또는 적어도 잠재적으로 그러하다가 수용과 동시에 타인의 우선권의 목적이 되는 것으로 현재화된 채권에 관하여 전부명령을 받은 데에 불과한 것으로서, 이로 인하여 담보권자의 물상대위권이 상실되거나 전부채권자가 담보권자에 우선하여 변제를 받을 수 있는 것은 아니고, 그 보상금이 실제로 전부채권자에게 지급되어 버리거나 그 보상금이 변제공탁된 후 전부채권자에게 출급되어 버리지 아니하였다면 담보권자는 여전히 물상대위권을 행사할 수 있다.

다. 그리고 이러한 법리는 저당권이 설정된 이후에 그 목적채권이 양도되어 제3채무자에 대한 대항요건을 구비한 후인 경우에도 동일하다고 볼 수 있다.⁷³⁵⁾ 이와 관련된 사례를 하나 보기로 한다.



735) 山崎 恒, 山田俊雄 編, 民事執行法[12], 青林書院(2001), 286. 이하; 近藤 基 編, 實務債權配當の基本問題, 民事法研究會(平成 13), 339.; 日最判 平成 10(1998), 1. 30.(判時 1628, 3)

이것은 저당권자의 물상대위에 의한 압류의 의미를 어떻게 이해하는가의 문제와 관련이 있는바, 이에 대해서는 ① 물상대위에 의한 압류의 의미를 대위목적물의 특정성에서 구하고, 저당권의 공시(등기)가 물상대위권의 공시로 된다는 견해⁷³⁶⁾ ② 물상대위에 의한 압류의 의미를 우선권의 보전 및 공시수단이라고 해석하는 견해⁷³⁷⁾ ③ 물상대위에 의한 압류의 의미를 우선권의 보전 및 채권의 특정성에서 구하는 견해 등이 나타나고 있으며, 그 중 위 ①의 견해에 따르면, 물상대위에 의한 압류와 채권양도의 우열은 저당권설정등기와 채권양도의 대항요건을 갖춘 시기의 전후에 따라 결정하게 되고, 위 ②설은 그 우열을 물상대위에 의해 압류한 때와 채권양도의 대항요건을 갖춘 때의 전후에 의해서 결정하게 된다.

우리 판례⁷³⁸⁾는 앞서 본 바와 같이 “민법 제370조, 제342조 단서가 저당권자는 물상대위권을 행사하기 위하여 저당권설정자가 받을 금전 기타 물건의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다고 규정한 것은 물상대위의 목적인 채권의 특정성을 유지하여 그 효력을 보전함과 동시에 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않으려는데 있는 것이므로 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 채권자보다 우선변제를 받을 수 있으나, 그 행사방법으로는 민사소송법 제733조에 의하여 담보권의 존재를 증명하는 서류를 집행법원에 제출하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 것이거나 민사소송법 제580조 제1항에 의하여 배당요구를 하는 것이므로 이러한 물상대위권의 행사에 나아가지 아니한 채 단지 수용대상토지에 대하여 담보물권의 등기가 된 것만으로는 그 보상금으로부터 우선변제를 받을 수 없다.”라고 판시하고 있어서 위 견해들 중 ③설을 취하고 있다고 보여진다.

이에 따르면, 저당권자의 물상대위에 의한 압류는 그 우선권 보전이 필요하다고 해석되므로 담보권의 효력은 대위물 위에 미치고 있는 것이 당연한 전제가 되어, 우선권은 압류의 순서가 아닌 원래의 담보권의 순위에 의하게 된다. 그러므로 이 견해에 의하더라도 위 ①설과 같이 물상대위에 의한 압류와 채권양도의 우열은 저당권설정등기일자와 채권양도의 대항요건을 구비한 시기의 전후에 따라 결정되게 될 것이다.

736) 吉野 衛, “物上代位に關する基礎的考察”, 金法 972号, 8.; 我妻榮(주424), 292. 등

737) 朝川, “保險金請求權に對する質權との優劣”, 法學新報64卷 9号, 39.

738) 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결; 그 외에 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다 25728 판결; 대법원 1999. 5. 14. 선고 98다62688 판결; 대법원 2000. 5. 12. 선고 2000다 4272 판결; 대법원 2000. 6. 23. 선고 98다31899 판결; 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다 33137 판결 등

그리고 담보물권의 목적물이 수용되었을 경우에 보상금에 대하여 당해 담보물권을 행사하기 위한 요건으로서 그 지급 전에 압류하여야 한다[민법 제370조, 제342조, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하, 공익사업토지보상법) 제47조].⁷³⁹⁾ 이와 같이 지급 전에 압류를 요하는 취지는, 보상금이 소유자의 일반재산에 혼입되기 전까지, 즉 물상대위의 목적이 되는 보상금의 특정성을 유지하여 제3자에게 불측의 손해를 입히지 아니하려는 데 있는 것이므로 사업시행자가 보상금을 변제공탁하였다고 하더라도 이 공탁금이 출급되기까지는 공익사업토지보상법 제47조⁷⁴⁰⁾ 단서가 규정하는 지급이 있었다고 할 수 없고, 이는 보상금의 변제의 효과와는 별개의 문제이다.⁷⁴¹⁾

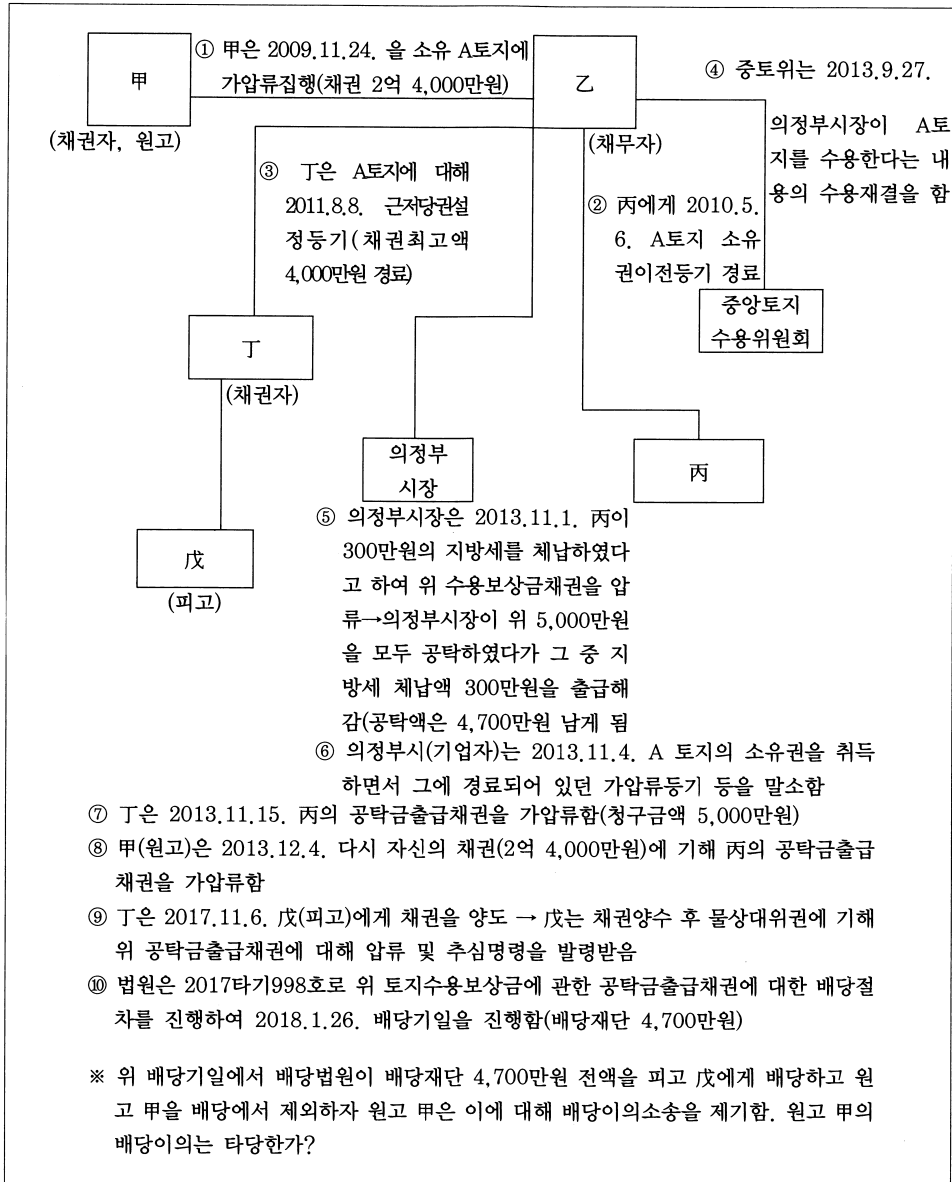
결국 위 사례의 경우 비록 위 보상금채권이甲의 압류 및 전부 이전에 다른 채권자乙에게 양도되고 그 대항요건까지 갖추었다고 하더라도 저당권설정일자가 위 양도의 대항요건보다 우선하므로乙은甲에게 대항할 수 없게 된다.乙이 사업인정고시 후甲보다 먼저 위 보상금채권에 대하여 압류 및 전부명령을 받았다고 하더라도 마찬가지이다.

라. 나아가 여기에서 토지수용보상금청구권에 대한 가압류채권자와 담보물권에 기한 물상대위권자와의 관계를 살펴보기 위해 사례를 하나 더 보기로 한다.

739) 사업인정의 고시가 있으면 수용대상토지에 대한 손실보상금의 지급이 확실히 되므로 토지수용의 재결 이전 단계에서도 물상대위권을 행사할 수 있다(대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결). 수용보상금이 공탁되기 이전에는 보상금지급청구권에 대하여 제3채무자를 사업시행자로, 공탁한 이후에는 공탁금출급청구권에 대하여 제3채무자를 국가(소관 공탁관)로 하여 압류하여야 한다.

740) 담보물권의 목적물이 수용 또는 사용된 경우 당해 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다. 다만 그 지급 전에 압류하여야 한다.

741) 대법원 1992. 7. 10.자 92마380, 381 결정【결정요지】[1] 근저당권에 기한 물상대위권을 갖는 채권자가 그 물상대위권을 행사하여 우선변제를 받음에 있어, 그 권리실행방법은 민사소송법 제733조에 의하여 채권에 대한 강제집행절차를 준용하여 채권의 압류 및 전부명령을 신청할 수 있다고 할 것이나, 이는 어디까지나 담보권의 실행절차이므로 그 요건으로서 담보권의 존재를 증명하는 서류를 제출하여 개시하면 되는 것이고, 일반채권자로서 강제집행을 하는 것이 아니므로 채무명의를 필요로 하지 않는다. [2] 토지수용법 제69조가 담보물권의 목적물이 수용되었을 경우 보상금에 대하여 당해 담보물권을 행사하기 위한 요건으로서 그 지불 전에 압류할 것을 요구하는 이유는, 보상금이 소유자의 일반재산에 혼입되기 전까지, 즉 특정성이 유지 보전되고 있는 한도 안에서 우선변제권을 인정하고자 함에 있다. [3] 토지수용에 있어 기업자가 보상금을 변제공탁하였다고 하더라도 이 공탁금이 출급되어 수용 대상 부동산 소유자의 일반재산에 혼입되기까지는 토지수용법 제69조 단서가 규정하는 지불이 있었다고 할 수 없고, 이는 보상금의 변제의 효과와는 별개의 문제라고 할 것이다.



우선 이 경우 공익사업토지보상법 제45조 제1항에 의하면, 기업자는 토지를 수용한 날에 그 소유권을 취득하고 그 토지에 관한 권리는 소멸하므로,⁷⁴²⁾ 수용되는

742) 대법원 1979. 9. 25. 선고 79다1369 판결; 대법원 1991. 11. 12. 선고 91다27612 판결; 대법원 1993. 11. 12. 선고 93다34756 판결; 대법원 1995. 9. 15. 선고 94다27649 판결; 대법원 1995. 12. 22. 선고 94다40765 판결 등 참조

토지에 대하여 가압류가 집행되어 있더라도 토지수용으로 기업자가 그 소유권을 원시 취득하게 됨에 따라 그 토지 가압류의 효력은 소멸하는 것이고, 이때 그 토지 가압류가 수용보상금채권에 당연히 전이되어 그 효력이 미치는 것이 아니다.⁷⁴³⁾

그러므로 수용 전 토지에 대한 가압류채권자가 다시 수용보상금채권에 대하여 가압류를 하였다 하더라도 수용 전 토지에 대하여 위 가압류 이후 저당권을 취득하였다가 위 수용보상금채권에 대하여 물상대위에 따른 압류를 한 자에 대하여는, 수용 전 토지에 관하여 주장할 수 있었던 사유를 수용보상금채권에 대한 배당절차에서까지 주장할 수는 없다.⁷⁴⁴⁾ 또한 토지수용에 있어 수용되는 토지에 설정되어 있던 담보권자는 공익사업토지보상법 제47조에 의해 물상대위권이 인정되므로 수용보상금에 대하여 일반 채권자보다 우선하여 변제받을 수 있으며, 담보권자로서는 여전히 토지가 수용된 이후에도 물상대위에 의하여 그 우선변제권이 그대로 유지되는 반면, 위에서 본 바와 같이 기존 가압류의 처분금지적 효력이 토지소유자가 지급 받을 수용보상금에 그대로 전이되어 그 효력이 미친다거나 수용보상금채권에 대하여도 토지 가압류의 처분금지적 효력이 여전히 미친다고 볼 법률상 근거가 없는 이상(토지가 수용되면 기업자가 그 소유권을 원시취득하고 그에 따라 당초 부동산에 대한 압류의 효력은 절대적으로 소멸한다), 가압류채권자는 기존의 가압류와 동일한 피보전채권에 기하여 다시 수용보상금청구권에 대하여 새로운 가압류를 하였다 하더라도, 이러한 가압류채권자는 당초 담보물권의 우선변제권의 효력이 그대로 유지되는 물상대위권자에게 우선할 수 없게 된다.

즉 위 사례에서 이 사건 토지의 수용으로 기업자(의정부시)가 그 소유권을 원시 취득함으로써 당초의 부동산 가압류의 효력은 절대적으로 소멸하게 되므로 새로이 위 수용보상금채권에 대한 가압류를 한 원고 甲이, 위 근저당권에 터잡아 위 수용보상금채권에 대하여 물상대위권을 행사한 피고 戊보다 우선하여 위 수용보상금을 배당받을 수는 없다.⁷⁴⁵⁾ ⁷⁴⁶⁾ 따라서 결국 위 사례에서 원고 甲의 배당이의소송은 인정되지 않게 될 것이다.

743) 대법원 2000. 7. 4. 선고 98다62961 판결

744) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001다83777 판결 참조

745) 대법원 2004. 4. 16. 선고 2003다64206 판결

746) 이 경우 만일 A토지에 대해 토지수용이 되지 않았다면 甲의 가압류의 처분금지적 효력으로 인하여 배당절차에서 甲만이 배당받게 될 것이다. 결국 甲은 우연하게 토지가 수용됨으로써 현저한 불이익을 입게 되는 것이다. 일본의 경우도 토지수용법상 가압류권자에 대한 보호 조항이 없어서 동일한 문제가 제기되었으나, 1967년 토지수용법 제96조를 개정하여 가압류권자 보호 조항을 신설함으로써 입법적으로 해결한 바 있다. 이에 관해 우리도 참고할 필요가 있다고 본다.

마. 저당권이 설정된 전세권의 존속기간이 만료된 경우에 저당권자는 민법 제 370조, 제342조 및 민사집행법 제273조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 압류 및 추심명령 또는 전부명령을 받는 등의 방법으로 권리를 행사하여 전세권설정자에 대해 전세금의 지급을 구할 수 있다.⁷⁴⁷⁾ 이때 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 일반 채권자가 물상대위권을 행사하려는 저당채권자보다 단순히 먼저 압류나 가압류의 집행을 함에 지나지 않은 경우에는 저당권자는 그 전은 물론 그 후에도 목적채권에 대하여 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수가 있고,⁷⁴⁸⁾ 위와 같이 전세권부 근저당권자가 우선권 있는 채권에 기하여 전부명령을 받은 경우에는 형식상 압류가 경합되었다 하더라도 그 전부명령은 유효하다.⁷⁴⁹⁾

IV. 채권담보권의 실행

1. 서

채권담보권이란 담보약정에 따라 금전의 지급을 목적으로 하는 지명채권(수개의 채권 또는 장래에 발생할 채권을 포함)을 목적으로 등기한 담보권을 말한다(동산채권담보법 제2조 제3항).

동산채권담보법은 채권담보권의 실행방식으로 담보권자가 피담보채권의 한도에서 담보목적채권을 직접 청구하는 사적 실행방법과 민사집행법에 의한 실행방법을 인정하고 있다(같은 법 제36조). 여기서는 민사집행법에 의한 실행방법만을 설명하기로 하는바, 채권담보권 실행절차는 민사집행법의 채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행절차에 의하도록 되어 있다(민집 제273조, 민집규 제200조).

이에 따라 채권담보권 실행절차는 신청 → 압류 → 현금화(추심명령, 전부명령 등) → 채권의 만족(배당)의 순서로 진행된다.

또한 앞서 말한 대로 동산채권담보법에 따른 동산담보권자는 담보목적물의 매각, 임대, 멸실, 훼손 또는 공용징수 등으로 인하여 담보권설정자가 받을 금전이나 그 밖의 물건에 대하여도 물상대위를 할 수 있는데(같은 법 제14조), 그 절차는 채권집행

747) 대법원 1999. 9. 17. 선고 98다31301 판결 참조

748) 대법원 1994. 11. 22. 선고 94다25728 판결 등 참조

749) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65396 판결

의 방식을 따르므로(같은 법 제36조 제3항, 민집 제273조), 이를 감안하여 여기에서 동산담보권에 기한 물상대위도 함께 논의한다.

※ 2019. 6. 현재 동산채권담보법의 개정작업이 진행 중이다. 개정 규정의 주된 내용은 ① 일괄담보제도의 도입, ② 동산채권담보법 적용대상 확대, ③ 사적 실행 등 집행절차 개선, ④ 담보권 존속기간 폐지, ⑤ 처벌규정 신설 등이다. ① 일괄담보제도의 도입은, 현행 동산담보제도가 자산별로 각 담보를 설정하도록 되어 있어 이중 재산(동산, 채권, 지식재산권, 부동산) 간의 일괄담보의 설정이 불가능하여 개별자산의 담보가치가 실제 가치보다 저평가될 우려가 있는 점, 자산별 담보설정 과정에서 감정평가비용, 등기비용, 경매비용이 각 발생하여 금전적 부담이 있는 점 등을 감안하여 동산·채권·지식재산권 사이에서 담보권의 일괄 설정을 가능하게 하고자 하는 것이다. 이를 위하여 일괄담보권의 정의규정을 신설하고, 일괄담보에 관한 별도의 장을 마련하며, 등기필정보 통지 내용에 일괄담보를 추가하는 것을 개정안으로 내놓고 있다. ② 동산채권담보법 적용대상 확대는, 동법이 적용되는 인적범위 제한 규정(현행 제2조 제5호 등)을 삭제하고, 압류금지되는 동산이나 채권은 담보설정을 금지하는 것을 내용으로 하고 있다. ③ 사적 실행 등 집행절차 개선은, 사적 실행의 요건을 법률에 명확하게 규정⁷⁵⁰⁾하고, 강제집행시 압류사실 통지의무를 부여하며 당연 배당 규정을 도입하고, 소제주의(강제집행으로 담보권 실행이 이루어지면 해당 담보권 위의 모든 권리는 담보목적물 매각에 의하여 소멸하도록 함)를 채택하는 것을 그 내용으로 한다. ④ 담보권의 존속기간 폐지는, 현행 제49조의 존속기간에 관한 조문을 삭제하고, 경매에서 말소등기 촉탁 및 담보권자의 말소 신청의 근거를 마련하는 것으로 내용으로 두고 있다. ⑤ 끝으로 처벌규정은, 담보물의 훼손·변형·은닉 등에 대한 처벌규정을 마련하고 이를 친고죄로 구성하는 것을 골자로 하고 있다.

2. 채권담보권 실행절차의 특징

가. ‘담보권에 기한’ 집행절차 : 채권담보권의 실행은 담보권에 기한 신청이므로 담보권의 효력이 미치는 범위를 기준으로 피압류채권이 특정된다. 이는 채권에 대한 강제집행의 경우 집행법원이 피압류채권의 존부, 귀속 등에 관하여 심사할 권한이 없

750) ㉠ 목적물의 가치 및 제반 부대비용을 감안할 때 과도한 비용을 들여 경매하는 것이 불합리한 경우 ㉡ 담보목적물이 부패·변질 또는 감량되기 쉬운 재산으로 속히 매각하지 아니하면 그 재산 가액이 줄어듦 우려가 있는 경우 ㉢ 대통령령이 정하는 공개시장에서 매각하는 경우 ㉣ 그 밖의 정당한 사유가 있는 경우

어(형식적 심사권) 신청채권자의 주장만으로 피압류채권이 특정되는 것과 대비되는 것이다. 따라서 담보권의 효력이 미치는 범위를 초과한 압류신청은 부적법하고, 이를 간과하고 발령된 압류명령도 부적법하다.

이는 담보권 실행을 위한 집행방법이므로, 절차상 사유뿐만 아니라 담보권의 부존재·소멸 등의 실체상 사유에 기한 불복이 허용된다(민집 제265조, 민집규 제200조 제2항). 집행절차의 정지·취소의 근거규정도 민사집행법 제49조, 제50조가 아니라 민사집행법 제266조가 된다(민집규 제200조 제2항).

그러나 압류금지채권에 관한 규정(민집 제246조 제1항, 제2항)과 압류금지 범위 변경에 관한 규정(민집 제246조 제3항, 제4항)은 원칙적으로 적용되지 않는다. 또한 우선변제의 대상인 채권담보권에 관하여, 압류효력의 확장에 관한 규정(민집 제235조)과 압류 등의 경합에 따른 전부명령의 무효에 관한 규정(민집 제229조 제5항)도 적용되지 않는다.⁷⁵¹⁾

나. ‘금전채권’에 대한 집행절차 : 채권담보권의 담보목적물은 금전의 지급을 목적으로 하는 지명채권에 한정된다(동산채권담보법 제34조 제1항). 따라서 금전채권에 대한 집행절차의 규정이 준용된다. 다만 동산담보권에 기한 물상대위의 목적물은 담보권설정자가 받을 금전 또는 물건이므로(동산채권담보법 제14조), 금전채권 또는 유체동산인도청구권 집행방법에 따른다.

다. ‘등기’담보권에 기한 집행절차 : 채권담보권의 공시방법은 등기이다.⁷⁵²⁾ 이는 채권질권과 다른 점이다. 등기담보권이라는 점에서 부동산담보권인 저당권 등과 유사하다. 따라서 담보권의 존재를 증명하는 서류에 관하여는 부동산담보권에 관한 규정을 준용한다(민집 제264조, 민집규 제200조 제2항, 동산·채권의 담보등기에 관한 규칙⁷⁵³⁾ 제55조)

라. 사적 실행절차와 민사집행법상 집행절차의 경합 : 동산담보권의 경우 사적 실행절차와 민사집행법상 경매절차가 경합하는 경우 경매우선주의를 규정하여 양 절차의 경합을 조정하는 규정을 두고 있으나(동산채권담보법 제23조 제5항), 채권담보권의 경우 그러한 취지의 명확한 조정규정을 두고 있지 않다.

751) 이는 일반채권자들 사이의 평등주의를 구현하기 위한 규정들이기 때문이다.

752) 이와 달리 양도담보의 공시방법은 확정일자 있는 증서에 의한 제3채무자에 대한 통지 또는 승낙이다.

753) 이하 ‘동산채권담보등기규칙’이라고 한다

3. 채권담보권의 성립과 효력

가. 채권담보권의 성립

1) 목적물

채권담보권의 목적물은 금전의 지급을 목적으로 하는 지명채권(수개의 채권 또는 장래에 발생할 채권을 포함)이다. 담보권설정자가 타인에게 이미 양도된 채권과 같이 처분권 없는 채권에 채권담보권을 설정하더라도 그 설정행위는 무효이므로 채권자는 채권담보권을 취득할 수 없고, 그것을 선의취득할 수도 없다.

담보목적물인 채권은 ① 이미 발생한 채권, ② 장래에 발생할 채권(채무자가 특정된 경우), ③ 장래에 발생할 채권(채무자가 특정되지 않은 경우) 등과 같이 세 가지 유형으로 나누어 볼 수 있다(동산채권담보등기규칙 제35조, 동산채권담보등기 신청예규⁷⁵⁴ 제6조 참조).

2) 담보권설정자

이는 동산채권담보법에 따라 채권에 담보권을 설정한 자를 말하는데, 법인 또는 상업등기법에 따라 상호등기를 한 자만이 담보권을 설정할 수 있다(같은 법 제2조 제5호).⁷⁵⁵ 다만 담보권설정자의 상호등기가 말소된 경우에도 이미 설정된 채권담보권의 효력에는 영향을 미치지 않는다(같은 법 제37조, 제4조).

채무자가 아닌 제3자도 담보권설정자가 될 수 있고(같은 법 제37조, 제8조, 제16조), 채권담보권을 설정하려는 자는 담보약정을 할 때 담보목적물의 소유 여부와 그에 관한 다른 권리의 존재 유무를 상대방에게 명시하여야 한다(같은 법 제37조, 제6조).

3) 담보권자

동산채권담보법에 따라 채권을 목적으로 하는 담보권을 취득한 자를 말한다(같은 법 제2조 제6호). 누가 담보권자가 될 수 있는지에 관하여는 아무런 제한이 없다(같은 법 제37조, 제5조 참조).

754) 이는 등기예규 제1493호, “동산·채권의 담보등기 신청에 관한 업무처리지침”을 말한다. 이하 같다.

755) 그러나 이에 대하여는 그 동안 담보권설정자를 법인 또는 상호등기를 한 사람으로 한정함으로써 상호등기를 하지 않은 자영업자 및 상호등기가 불가능한 자 등은 동산담보제도의 혜택을 받을 수 없고, 상호등기 여부로 담보권설정자를 제한할 필요성이 적으며 개인이 동산담보제도를 이용하는 것을 막을 이유가 없다는 비판이 제기되고 있었다. 이에 2019. 6. 현재 위와 같이 담보권 설정자의 인적범위를 법인 또는 상호등기를 한 사람으로 한정하는 규정을 삭제하되, 다만 개인도 동산담보권을 설정할 수 있게 됨에 따라 대부업자 등의 제도 악용 우려가 있으므로 개인의 피해 예방을 위해 민사집행법에 따라 압류가 금지되는 동산·채권을 담보권의 목적으로 할 수 없도록 규정을 개정하는 입법논의가 진행되고 있다.

4) 담보약정

담보약정은 양도담보 등 명목을 묻지 않고 동산채권담보법에 따라 채권을 담보로 제공하고자 하는 약정을 말한다(같은 법 제2조 제1호).

5) 담보등기

채권담보권을 가지고 채무자 이외의 제3자에게 대항하기 위해서는 담보권설정자의 채권을 담보로 제공하기로 약정하고 담보등기를 하여야 한다(같은 법 제35조 제1항). 담보등기는 동산채권담보법에 따라 채권을 담보로 제공하기 위하여 이루어진 등기를 말한다(같은 법 제2조 제7호). 담보등기부는 전산정보처리조직에 의하여 입력·처리된 등기사항에 관한 전산정보자료를 담보권설정자별로 저장한 보조기억장치(자기디스크, 자기테이프, 그 밖에 이와 유사한 방법으로 일정한 등기사항을 기록·보존할 수 있는 전자적 정보저장매체를 포함)를 말한다(같은 법 제2조 제8호). 담보등기는 채권담보권의 설정, 이전, 변경, 말소 또는 연장에 대하여 행해지고(같은 법 제38조), 담보등기부는 이른바 인적편성주의를 채택하여 담보목적물인 채권의 등기사항에 관한 전산정보자료를 전산정보처리조직에 의하여 담보권설정자별로 구분하여 작성한다(같은 법 제47조 제1항). 담보등기부에 기록할 사항은 동산채권담보법 제47조 제2항이 규정하고 있다.

담보권설정자와 담보권자는 담보약정의 취소, 해제 또는 그 밖의 원인으로 효력이 발생하지 않거나 효력을 상실한 경우, 담보목적물인 채권이 소멸한 경우, 그 밖에 담보권이 소멸한 경우의 어느 하나에 해당하는 경우에 말소등기를 신청할 수 있다(같은 법 제50조 제1항).

나. 채권담보권의 효력

1) 기존 담보제도와의 비교

금전채권을 담보목적물로 하여 담보권을 취득하는 제도에는 채권담보등기 제도 이외에도 민법상 채권질권 제도와 판례가 인정하는 채권양도담보권 제도 등이 있다. 채권양도담보권은 존속기간의 제한 유무, 제3자 대항요건 구비방법, 방어적 기능의 유무, 배당절차에서의 취급 등에 있어서 채권담보권과 차이가 있으며, 어느 한 쪽 제도가 특히 유리한 것이라고 단정하기는 어렵다. 따라서 채권자는 담보권설정자의 신용상태, 해당 담보제도의 장단점 등 여러 사정을 고려하여 적합한 담보제도를 이용하면 될 것이다.

2) 담보물권적 특성

채권담보권도 다른 담보물권과 마찬가지로 우선변제권(같은 법 제37조, 제8조), 부종성(같은 법 제37조, 제33조, 민법 제369조), 불가분성(같은 법 제27조, 제9조),

수반성(같은 법 제37조, 제13조) 등이 인정된다.

3) 피담보채권

채권담보권은 피담보채권의 원본, 이자, 위약금, 담보권실행의 비용, 채무불이행으로 인한 손해배상채권 등을 담보한다(같은 법 제37조, 제12조 본문). 다만 이는 임의규정이므로 설정행위로 다른 약정이 있으면 그에 따른다(같은 법 제12조 단서). 민법의 저당권에서와 같은 지연배상의 제한(민법 제360조 단서)은 적용되지 않는다.

실무상 채권담보권의 설정은 대부분 근담보권으로 설정하고 있다(같은 법 제37조, 제5조 참조). 이 경우 피담보채권의 범위, 확정사유 등의 법률관계에 관하여는 대체로 근저당권의 법리를 적용하면 될 것이다.

4) 담보목적물인 채권

채권담보권의 효력은 그 목적물인 채권에 대하여 미친다(같은 법 제37조, 제10조).

채권담보권이 설정된 담보목적물인 채권(채권담보권의 부담 있는 채권)을 양수하는 경우 동산담보권에 대한 선의취득규정(같은 법 제32조, 민법 제249조부터 제251조)은 채권담보권의 성질에 반하기 때문에(같은 법 제37조) 준용되지 않는다 할 것이다. 따라서 설정자가 채권담보권이 설정된 채권을 다시 제3자에게 양도하는 경우 양수인이 채권담보권의 존재에 대하여 선의·무과실이더라도 채권담보권의 부담이 있는 채권을 승계취득하게 될 뿐이다.

5) 담보등기의 효력

약정에 따른 채권담보권의 득실변경은 담보등기부에 등기한 때에 담보목적물인 채권의 채무자 외의 제3자에게 대항할 수 있다(같은 법 제35조 제1항). 동일한 채권에 대하여 설정된 채권담보권의 순위는 등기순서에 따른다(같은 법 제37조, 제7조 제2항). 동일 채권에 대하여 채권담보권과 민법 제349조의 채권질권 또는 민법 제450조 제2항의 채권양도에 따른 통지 또는 승락이 경합하는 경우에 채권담보권자, 채권질권자, 담보목적물인 채권의 양수인 상호간의 우열은 법률에 다른 규정이 없으면 담보등기와 그 통지의 도달 또는 승낙의 선후에 의하여 결정한다(같은 법 제35조 제3항).

채권담보권자가 담보등기를 마친 후에서야 동일한 채권에 관한 채권양도가 이루어지고 확정일자 있는 증서에 의한 채권양도의 통지가 제3채무자에게 도달하였으나, 동산채권담보법 제35조 제2항에 따른 담보권설정의 통지는 제3채무자에게 도달하지 않은 상태에서는, 제3채무자에 대한 관계에서 채권양수인만이 대항요건을 갖추었으므로 제3채무자로서는 채권양수인에게 유효하게 채무를 변제할 수 있고 이로써 채권담보권자에 대하여도 면책된다. 다만 채권양수인은 채권담보권자에 대한 관계에서는 후순위로서,

채권담보권자의 우선변제적 지위를 침해하여 이익을 받은 것이 되므로, 채권담보권자는 채권양수인에게 부당이득으로서 변제받은 것의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 그 후 동산채권담보법 제35조 제2항에 따른 담보권설정의 통지가 제3채무자에게 도달한 경우에는, 그 통지가 채권양도의 통지보다 늦게 제3채무자에게 도달하였더라도, 채권양수인에게 우선하는 채권담보권자가 제3채무자에 대한 대항요건까지 갖추었으므로 제3채무자로서는 채권담보권자에게 채무를 변제하여야 하고, 채권양수인에게 변제하였다면 특별한 사정이 없는 한 이로써 채권담보권자에게 대항할 수 없다.⁷⁵⁶⁾ 채권담보권자가 채권양수인보다 우선하고 담보권설정의 통지가 제3채무자에게 도달하였는데도, 그 통지보다 채권양도의 통지가 먼저 도달하였다는 등의 이유로 제3채무자가 채권양수인에게 채무를 변제한 경우에 채권담보권자가 무권한자인 채권양수인의 변제수령을 추인하였다면, 추인에 의하여 제3채무자의 채권양수인에 대한 변제는 유효하게 되는 한편 채권담보권자는 채권양수인에게 부당이득으로서 변제받은 것의 반환을 청구할 수 있다.⁷⁵⁷⁾

6) 존속기간

채권담보권의 존속기간은 5년을 초과할 수 없으므로(같은 법 제49조 제1항 본문), 설정 후 존속기간(최장 5년)이 경과한 채권담보권은 소멸하게 된다.⁷⁵⁸⁾ 다만 5년을 초과하지 않는 기간으로 이를 갱신할 수 있는데(같은 법 제49조 제1항 단서), 설정자와 담보권자는 존속기간을 갱신하려면 그 만료 전에 연장등기를 신청하여야 하고(같은 법 제49조 제2항, 제3항), 그 연장등기를 위하여 담보등기부에 존속기간을 연장하는 취지와 연장 후의 존속기간을 기록하여야 한다(같은 법 제49조 제3항). 갱신의 횟수는 제한이 없다.⁷⁵⁹⁾

4. 채권담보등기

가. 담보목적물인 채권의 특정

1) 특정의 필요성

어느 채권이 담보목적물인 채권에 해당하는지 여부는 담보권 실행의 대상인 피

756) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015다71586, 71863 판결

757) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015다71586, 71863 판결

758) 이와 달리 양도담보의 경우에는 존속기간의 제한이 없다.

759) 그러나 이에 대하여는 그 동안 상사채권의 소멸시효 기간이 5년인 점 등을 고려하여 담보권의 존속기간을 일률적으로 상정한 것인바, 담보권상실 위험 및 연장등기 비용 등 채권자가 연장에 대한 부담으로 대출만기를 축소하여 영세한 차주의 자금조달 수단을 오히려 제한하고 있다는 비판이 제기되어 왔는바, 앞서 본 대로 2019. 6. 현재 이 규정에 따른 존속기간을 폐지하고 위 규정을 삭제하는 것으로 개정작업이 진행 중이다.

압류적격 인정 여부 등을 결정하는 기준이 된다. 따라서 그 특정을 위해 필요한 사항은 필수적 등기사항으로 되어 있다(같은 법 제47조 제2항 제6호, 동산채권담보등기 규칙 제35조, 동산채권담보등기 신청예규 제6조).

담보권에 기한 압류 등 신청인은 담보목적물에 표시된 채권을 기준으로 신청서의 피압류채권 표시를 하여야 하고, 집행법원도 담보목적물부에 표시된 채권을 기준으로 압류명령을 발령하여야 한다.

2) 특징요소

가) 필수적 요소와 유익적 요소 : 담보목적물인 채권은 5개의 필수적 요소(필수적 등기사항)와 그 밖의 유익적 요소(유익적 등기사항)가 그 특정을 위한 요소에 해당하므로⁷⁶⁰⁾ 이를 기준으로 담보목적물인 채권인지 여부를 결정하게 된다.

필수적 요소는, ① 동산채권담보등기 신청예규 별표 제1호에 따른 채권의 종류(부동산매매대금채권, 동산매매대금채권 등 모두 24개의 채권이 열거되어 있음), ② 채권의 발생원인 및 발생연월일 또는 그 시기와 종기, ③ 담보목적물인 채권의 채권자의 성명 및 주소(법인의 경우에는 상호 또는 명칭과 본점 또는 주된 사무소), ④ 담보목적물인 채권의 채무자의 성명 및 주소(법인의 경우에는 상호 또는 명칭과 본점 또는 주된 사무소), ⑤ 담보목적물인 채권의 일련번호 등을 말한다(동산채권담보등기 신청예규 제6조 제1항 제2호 가목부터 마목). 다만 장래채권 중 채무자가 특정되어 있지 않은 경우 채무자에 관한 사항은 기록하지 않을 수 있다(동산채권담보등기 신청예규 제6조 제2항).

유익적 요소는 위 5개의 필수적 등기사항에는 포함되지 않으나 담보목적물인 채권을 특정하는 데 유익한 사항으로서 채권의 변제기, 채권액, 증서번호 등을 의미한다(동산채권담보등기 신청예규 제6조 제3항).

나) 특정방법 : ① 이미 발생한 채권의 경우에는, 예컨대 채권의 종류란에 '동산매매대금채권'을, 채권의 발생원인 및 발생연월일란에 '2018년 6월 8일 기계류 판매계약'을, 목적채권의 채권자 및 채무자란에 각 성명 및 주소를 기재하면 된다. ② 장래에 발생할 채권으로서 채무자가 특정되어 있는 경우에는 그 시기와 종기를 기재해야 한다. 그리하여 예컨대 채권의 종류란에 '차임채권'을, 채권의 발생원인 및 발생연월일란에 '시기 2018년 1월 1일, 종기 2018년 12월 31일, 서울특별시 서초구 서초대로 10 ○○빌딩 301호 상가건물 임대차계약' 등으로 적으면 된다.

⁷⁶⁰⁾ 동산채권담보등기 신청예규 제6조 참조

③ 장래에 발생할 채권으로서 채무자가 특정되지 않은 경우에는 채무자를 특정하지 않고 채권담보권을 설정할 수 있다.⁷⁶¹⁾ ⁷⁶²⁾

그리하여 예컨대 채권의 종류란에 ‘차입채권’을, 채권의 발생원인 및 발생연원일란에 ‘시기 2018년 1월 1일, 종기 2018년 12월 31일, 甲 주식회사의 乙에 대한 서울특별시 서초구 서초대로 10 ○○빌딩 301호 상가건물 임대차계약’이라고 각 기재하고 채권자 및 채무자란에 채무자는 기재하지 않을 수 있다. 그러나 이 경우 등기단계에서 채무자를 특정하지 않을 수 있으나, 담보권 실행을 위한 압류명령을 신청하는 단계에서는 그 신청서에 반드시 채무자를 특정하여야 한다(민집규 제200조 제1항, 압류명령 신청서에는 그 채무자가 제3채무자가 될 것이다).

한편 담보권설정 당시 이미 발생한 채권과 채무자가 특정되어 있지 않은 장래에 발생할 채권을 함께 담보로 제공하는 경우 동시에 담보등기가 가능하다(동산채권담보등기 신청예규 제6조 제2항 제2호). 채무자가 특정되어 있는 이미 발생한 채권의 경우에는 채권 특정방법으로 채무자를 기재하여야 하지만, 채무자가 특정되어 있지 않은 장래에 발생할 채권과 동시에 담보로 제공하는 경우로서 전체적으로 보아 채무자가 특정되어 있지 않다고 볼 수 있는 경우에는 채권발생의 시기 및 종기와 채권의 변제기, 채권액, 증서번호 등 유의적 기재사항으로써 특정가능하면 채무자를 기재하지 않을 수 있다.

④ 동산의 특성에 따라 담보목적물을 특정(동산의 종류, 보관장소/특성, 기타사항 등을 특정)하여 등기함으로써 개별동산담보권이 설정된 경우, 위 동산이 매각, 임대, 멸실, 훼손 또는 공용징수된 경우에는 담보권자는 담보권설정자가 받을 금전이나 그 밖의 물건에 대하여 물상대위를 행사할 수 있고,⁷⁶³⁾ 이 경우 그 지급 또는 인도

761) 또한 다른 예로서 계속적 거래관계에 있는 상대방에 대한 매매대금채권처럼 담보권 설정 당시의 계속적 거래의 상대방이 채무자가 될 개연성이 높지만 채무자가 변경될 가능성이 있는 경우에도 채무자를 특정하지 않을 수 있을 것이다.

762) 장래에 발생할 채권으로서 채무자가 특정되지 않은 경우에 채권담보등기를 할 수 있다는 것은 다음과 같은 점에서 중요한 의미를 갖는다. 즉 ① 경합하는 제3자에 대한 대항요건 구비의 비용을 절감할 수 있다는 점(담보설정 당시 수많은 제3채무자가 존재할 경우 기존의 채권담보제도를 이용한다면 확정일자 있는 증서에 의한 통지를 일일이 송달시키기 위해 많은 비용과 노력이 드는데 채권담보등기를 이용하면 그러한 노력과 비용을 절감할 수 있음)과 ② 담보권 설정 당시 제3채무자가 특정되어 있지 아니한 채권도 담보로 활용할 수 있다는 점(제3채무자가 아직 특정되어 있지 아니한 채권의 경우 기존의 채권담보제도를 이용할 경우 제3자에 대한 대항요건을 취득할 방법이 없으나, 채권담보등기제도를 이용하면 담보설정 당시에 제3채무자가 존재하지 않더라도 등기가 가능하므로 제3자에 대한 대항요건을 구비할 수 있음)이 그것이다.

763) 물상대위의 원인이 매각인 경우에는 매매대금채권, 임대인 경우에는 차입채권, 멸실 또는 훼손인 경우에는 손해배상채권 또는 보험금채권, 수용인 경우에는 수용보상금채권이 대위목적채권이 된다.

전에 압류하여야 한다(같은 법 제14조). 압류를 할 때에는 담보권의 존재를 증명하는 서류인 동산담보등기부를 제출하여야 한다(민집 제273조 제2항). ⑤ 담보목적물이 동산의 보관장소에 따라 특정되는 집합동산이고 담보권설정자가 이를 매각하는 경우에는, ㉠ 당해 목적물의 매각이 통상의 영업범위 내 매각이라면 매매대금에 대한 물상대위는 허용되지 않지만, ㉡ 통상의 영업범위를 초과하는 매각일 경우에는 물상대위가 허용된다.⁷⁶⁴⁾

다) 시기와 종기 : 특정요소 중 시기와 종기를 한정한다는 것은 담보권의 효력이 미치는 범위를 한정한다는 것을 의미하므로 집행절차에 중대한 영향을 미치게 된다. 즉 동산채권담보등기 신청예규에 의하면 담보권설정당시 아직 발생하지 않은 장래채권에 대한 등기는 시기와 종기를 한정하는 방식으로 등기하게 되는데, 이는 집행절차에 있어서 담보권에 기한 압류명령의 피압류적격을 제한하고, 나아가 담보권자의 우선변제권을 제한하게 된다. 예를 들어, 담보목적채권이 2018년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 차임채권이라고 등기하고 2024년 2월 3일에 채권담보권에 기한 압류명령을 발령할 경우 피압류채권에 2024년 1월분의 차임채권을 포함시킬 수는 없으며, 제3채무자는 그에 대하여 집행공탁을 할 수도 없으며 다른 일반채권자의 압류가 경합하는 등의 사유로 집행공탁을 한다 해도 배당단계에서 2024년 1월분 차임채권으로부터는 우선변제를 받을 수도 없다. 이와 같이 담보목적채권의 시기와 종기를 한정하도록 한 것은 담보권이 미치는 효력을 제한한다는 의미에서 중요한 의미를 갖고 있다.

또한 종기를 변경하려면 다시 등기를 해야 하는데, 등기를 위한 시간과 비용이 드는 것은 물론이고 동일 채권에 대하여 다른 후순위권리자가 있는 경우 기존 등기의 순위 등 동일성을 유지하는 연장등기와 달리 재등기는 기존 등기와는 다른 별개의 새로운 등기이므로 그 우선순위가 역전될 수도 있다. ‘존속기간’에 대해서는 연장등기가 허용되지만, ‘종기’에 관하여는 변경등기가 허용되지 않음을 주의해야 한다.

민법상 채권질권, 판례상 인정되는 채권양도담보의 경우에는 이러한 시기와 종기의 제한을 두고 있지 않으므로 이러한 점에서 채권담보권보다 유리한 면이 있다.

764) 다만 이러한 ‘통상의 영업범위 내’ 여부라는 기준이 동산채권담보법 제14조가 인정하는 모든 물상대위에 동일하게 적용되는 것은 아니다. 예를 들어 양식시설의 양식어를 소유하는 甲 주식회사가 적조 등으로 인한 양식어의 폐사시 보험금을 받을 수 있는 보험계약을 체결한 후 A 은행과 위 양식어에 대한 집합동산담보권을 설정하였는데, 실제 위 양식어가 적조로 폐사한 경우, A는 담보권설정자 甲 회사가 위 양식어를 판매하여 영업을 계속할 것을 전제로 집합동산담보권을 취득하였다고 보아야 한다. 따라서 양식어가 폐사하였더라도 甲 회사가 통상의 영업을 계속하고 있는 한, 원칙적으로 위 보험금청구권에 대한 물상대위권을 행사할 수 없다고 보아야 한다.

나. 등기사항증명서

1) 등기사항증명서의 구성

담보등기부는 동산담보등기부와 채권담보등기로 구분되고, 등기기록은 담보권설정자별로 편성된다(인적편성주의).⁷⁶⁵⁾ 등기기록은 담보권설정자부, 담보권부, 담보목적물부로 구성된다.

등기사항증명서는 담보약정별로 발급된다(담보약정마다 등기일련번호를 부여함). 따라서 수개의 담보약정을 하나의 등기사항증명서로 발급받을 수 없다. 예를 들어 甲은행이 담보권설정자 A의 매매대금채권에 관하여 2018. 9. 15. 담보약정 및 담보등기를 마치고 나서 또 2018. 10. 15. 담보약정 및 담보등기를 마친 경우, 각 담보권의 내용 및 담보목적물에 관한 사항을 파악하려면 2개의 등기사항증명서를 발급받아야 한다.⁷⁶⁶⁾

등기사항증명서는 등기사항개요증명서(등기기록 미개설)를 제외하고는 담보권설정자부, 담보권부, 담보목적물부에 기록된 등기사항을 증명한다.

2) 등기사항증명서의 종류

가) 등기사항전부증명서 : 이는 하나의 담보약정에 따른 등기사항 전부를 증명하는 것인데, 말소사항까지 포함하여 전체를 기록하는 증명서[등기사항전부증명서(말소사항 포함)]와 말소사항을 제외하고 현재 유효한 사항만을 기록하는 증명서[등기사항전부증명서(현재 유효사항)]로 나뉘어진다. 채권담보권에 기한 압류 등을 신청할 경우에 담보권의 존재를 증명하는 서류는 등기사항전부증명서가 될 것이다.

나) 등기사항일부증명서 : 이는 하나의 담보약정에 따른 등기사항 중 담보목적물에 관하여 등기사항증명서를 발급받고자 하는 자가 신청한 특정한 담보목적물에 관한 사항만을 증명하는 서면을 말하는 것으로서 담보목적물인 채무자가 다수일 때 각각의 채무자에게 통지하는 경우 등에 있어서 이용될 수 있다. 담보권설정자부와 담보권부의 기록은 등기사항전부증명서와 동일하다.

다) 등기사항개요증명서 : 이는 하나의 담보권약정에 따른 등기사항 중 개요사항만을 기록한 서면이다. 개요사항은 ① 담보권설정자부에 기록된 사항, ② 담보권부의 순위번호란, ③ 등기목적란, ④ 접수란, ⑤ 등기원인란에 기록된 사항 중 현재 유효

765) 최초 담보권설정등기시 등기고유번호를 부여한다.

766) 이러한 점은 1개의 등기사항증명서를 발급받으면 수개의 담보권의 내용을 파악할 수 있는 부동산 등기사항증명서와 다른 부분이다.

한 사항, ⑥ 담보목적물부에 기록된 현재 유효한 목적물의 개수를 말한다. 또한 해당 법인 또는 상호등기를 한 자에 대하여 아무런 등기기록이 개설되어 있지 않다는 내용(담보권설정등기를 전부 말소하여 해당 등기기록을 폐쇄한 경우 포함)을 증명하는 등기사항개요증명서(등기기록 미개설)의 발급도 가능하다.⁷⁶⁷⁾

등기사항개요증명서에 대하여는 발급신청권자의 제한이 없다. 동산채권담보등기의 내용을 법률상 이해관계가 없는 제3자에게도 공시할 필요가 있다는 데서 도입된 것이다.

3) 발급의 제한

등기사항증명서 중 전부증명서 및 일부증명서에 대하여는 담보등기의 당사자 등 법률상 이해관계가 있는 일정한 사람에 한정하여 직접 이해관계가 있는 범위 내에서 발급을 신청할 수 있다. 이는 부동산등기사항증명서와 다른 점이다. 위 증명서 등에는 담보권설정자의 영업이나 신용에 관련된 정보가 여과 없이 노출될 수 있기 때문에 이와 같이 발급신청권자를 제한한 것이다. 따라서 법률상 이해관계가 없는 제3자는 등기사항개요증명서를 발급받아 개략적인 내용을 파악하는 수밖에 없다.

발급신청권자는 ① 담보권설정자, ② 담보권자, ③ 채무자, ④ 담보권설정 후 담보목적물을 취득한 사람, ⑤ 담보권설정 후 담보목적물에 대하여 질권이나 그 밖의 담보권을 취득한 사람, ⑥ 담보목적물인 채권의 채무자, ⑦ 그 밖에 당해 담보등기에 관하여 법률상 이해관계를 갖는 사람, ⑧ 위 사람의 파산관재인 등 관리처분권을 갖는 사람에 한정되고 있다. 따라서 담보등기 전의 채권자는 이러한 발급신청권자에 포함되지 않는다.⁷⁶⁸⁾

5. 집행의 신청

가. 관할

채권담보권에 기한 압류의 관할법원은 담보권설정자와 피담보채권의 채무자가 일치하는 경우에는 담보권설정자의 보통재판적 소재의 지방법원으로 되고(동산채권담보법 제36조, 민집 제273조 제3항, 제224조 제1항), 양자가 다른 경우에는 압류의

767) 담보권자는 대출 전에 이를 통하여 담보권설정자가 기존에 담보등기를 하였는지 여부에 관한 기초정보를 확인해 볼 수 있을 것이다.

768) 이 경우 채권자는 대출 전에 등기사항개요증명서를 직접 발급받거나 담보권설정자로부터 제출받아 다른 담보권이 존재하는지 여부를 확인한 다음 만일 다른 담보권이 설정되어 있다면 등기사항전부증명서를 제출받아 추가확인절차를 거친 후 대출 여부를 결정함이 좋을 것이다.

목적물인 채권의 채권자, 즉 담보제공자가 집행채무자이므로 담보권설정자를 기준으로 토지관할을 정해야 한다.⁷⁶⁹⁾

나. 신청서 기재사항

신청서에는 민사집행규칙 제192조에 규정된 사항을 적어야 한다(동산채권담보등 기규칙 제55조, 민집규 제200조, 제192조).

1) 표제

신청서에는 어떤 담보권에 기한 신청인가를 명확히 할 필요가 있다. 따라서 실행담보권의 유형에 따라 「채권압류명령신청서(동산·채권 등의 담보에 관한 법률의 채권담보권에 기한 신청)」⁷⁷⁰⁾ 또는 「채권압류명령신청서(동산·채권 등의 담보에 관한 법률의 동산담보권에 기한 물상대위를 위한 신청)」⁷⁷¹⁾이라고 그 표제를 적는다.

2) 당사자의 표시

강제집행의 경우 채권자 및 채무자는 집행문을 기준으로, 피압류채권과 제3채무자는 채권자의 주장을 기준으로 정해지는 데 반해, 채권담보권의 경우 등기담보권이므로 등기사항증명서를 기준으로 정해진다.

가) 채권자·채무자·담보권설정자의 표시(민집규 제192조 제1호) : 채무자와 담보권설정자가 일치하는 경우에는 담보목적 채권을 갖는자(담보권설정자)도 집행채무자가 되므로 「채무자 겸 담보권설정자」로 표시한다. 물상보증의 경우처럼 양자가 다를 경우에는 「채무자」 외에 물상보증인을 「담보권설정자」로 표시한다.

동산담보권에 기한 물상대위신청의 경우 채권자와 제3채무자의 표시는 채권담보권에 기한 경우와 같지만, 피압류채권을 가진 자(동산담보권설정자)도 집행채무자로 된다. 따라서 채무자와 피압류채권을 가진 자가 같은 경우 채무자 표시는 「채무자 겸 소유자」로 기재하고, 물상보증인이 동산담보권을 설정한 경우처럼 채무자와 피압류채권을 가진 자가 다르면 「채무자」 외에 「소유자」를 표시하여야 한다.

나) 제3채무자의 표시(민집규 제200조 제1항) : 담보권 설정 당시 이미 채권이 발생한 경우와 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우에는 담보목적물부의 '목적채권의 채무자'를 제3채무자로 기재한다. 장래발생채권으로서 채무자가 특정되지 않는

769) 부동산담보권자가 수용보상금에 대하여 물상대위를 할 때에도 실무상 수용보상금 수령권자인 담보권설정자를 기준으로 토지관할을 정하고 있다.

770) 별지서식 [3-16] 채권담보권에 기한 압류 및 추심(전부)명령 신청 참조(제3장 말미 수록)

771) 별지서식 [3-17] 동산담보권 물상대위를 위한 압류 및 추심(전부)명령 신청 참조(제3장 말미 수록)

경우와 같이 ‘목적채권의 채무자’가 불특정인 장래채권인 경우에는 제3채무자가 담보목적물에 나타나지 않으므로 채권의 발생원인 및 발생연월일 등에 의하여 담보목적물을 특정한다. 그리하여 예컨대 담보목적 채권이 ‘甲 주식회사의 乙에 대한 서울특별시 서초구 서초대로 10 ○○빌딩 301호 상가건물 임대차계약에 따른 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 차임채권’이라면 압류명령 신청 당시 위 ‘서울특별시 서초구 서초대로 10 ○○빌딩 301호 상가건물에 거주하는 임차인’을 제3채무자로 표시한다. 위와 같이 담보권 실행을 위한 압류명령 신청단계에서는 목적채권 채무자를 특정하지 않은 신청은 허용되지 않으므로 목적채권의 채무자(압류명령 신청서에는 제3채무자)가 반드시 기재되어야 한다. 따라서 압류명령 신청 당시에 위 상가건물에 입주하고 있는 임차인이 10명이고, 이들에 대한 차임채권을 집행할 경우에 그 피압류채권은 10개, 제3채무자는 10명이 될 것이다.

개별동산담보권에 기한 물상대위에 있어서 담보목적물인 개별동산이 다른 사람에게 매각되어 매매대금채권이 발생한 경우에는 담보목적물의 매수인이 제3채무자가 된다. 담보목적물이 동산의 보관장소에 따라 특정되는 집합동산이고 담보권설정자가 이를 매각하는 경우에는, ㉠ 당해 목적물의 매각이 통상의 영업범위 내 매각이라면 매매대금에 대한 물상대위는 허용되지 않고, ㉡ 통상의 영업범위를 초과하는 매각일 경우에는 물상대위가 허용되므로, 그때의 매수인을 제3채무자로 표시하면 된다.

3) 담보권 및 피담보채권의 표시(민집규 제192조 제2호)

담보권은 부동산 저당권의 경우와 동일하게 압류신청의 기초가 되는 담보권을 특정할 수 있도록 기재한다. 이는 등기사항증명서의 담보권부를 기준으로 하면 될 것이다.

피담보채권에 관하여도, 부동산 저당권에 준하여 등기사항증명서의 담보권부를 기준으로 신청서에 피담보채권을 기재한다. 피담보채권 중 일부에 대하여 담보권 실행을 하는 때에는 그 취지와 범위를 기재하고(민집규 제192조 제4호), 청구금액의 확장에 관한 문제는 동산담보권 및 부동산 저당권과 동일하게 보면 될 것이다.

4) 채권의 표시

가) 담보권 실행의 대상인 채권의 표시(민집규 제192조 제3호)

(1) 채권의 표시는 일반 압류명령 신청의 경우와 같이 피압류채권 목록에 기재하면 된다. 이러한 피압류채권의 표시는 압류의 효력으로서의 처분금지, 변제금지 등 구속을 받는 채권에 해당하는지 않는지를 구별하는 기준이 된다. 따라서 담보목적물부를 기준으로 명확히 기재할 필요가 있다.

다만 예를 들어 담보목적채권이 주택임차인의 임대차보증금반환채권인 경우에는 압류금지문구를 기재해서는 안 되고, 임대인의 차입채권인 경우에는 시기와 종기를 한정하여 압류하여야 하는 등 담보권의 효력이 미치는 범위에 의하여 피압류적격이 결정된다는 점이 일반 압류명령 신청의 경우와 다른 점이라고 볼 수 있다.

(2) 담보목적물인 채권을 특정하는 사항으로서 담보목적물부의 채권의 종류, 채권의 발생원인과 발생연월일 또는 그 시기와 종기, 목적채권의 채권자 및 채무자 등을 기재한다. 피압류채권의 특정에 도움이 된다면 기타사항에 유익적 기재사항으로서 변제기, 채권액, 증서번호 등을 기재할 수도 있다.

설정 당시 이미 채권이 발생한 경우라면 피압류채권은 “甲 주식회사의 乙 주식회사에 대한 2018년 6월 30일 ○○기계류 판매계약에 기한 동산매매대금채권” 등의 방식으로 기재하면 된다. 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우에는 “甲 주식회사의 乙에 대한 서울특별시 서초구 서초대로 ○○ ○○빌딩 ○○○호 상가건물 임대차계약에 기하여 발생하는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 차입채권”으로 기재하면 되고,⁷⁷²⁾ 장래발생채권으로 채무자가 특정되지 않는 경우에는 “甲 주식회사의 서울특별시 서초구 서초대로 ○○ ○○빌딩 상가건물 ○○○호에 대한 임대차계약에 기하여 발생하는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 차입채권” 등의 방식으로 기재한다. 이 경우 압류명령 신청 당시를 기준으로 위 상가건물에 임차 중인 사람을 특정하여야 한다.

나) 물상대위 목적인 금전채권의 표시

(1) 동산담보권에 기한 물상대위의 경우에는 담보목적물인 동산과 물상대위 목적채권의 관계를 나타내기 위하여 동산담보등기사항증명서의 담보목적물부의 동산의 종류, 보관장소/특성, 기타사항 등을 기재하고, 물상대위 목적채권의 유형(물상대위 원인이 매각인 경우 그 매매대금채권)을 적는다.

(2) 개별동산담보권의 경우, 담보목적물인 개별동산이 멸실되어 보험금청구권이 발생하였거나 개별동산이 타에 매각되어 매매대금이 발생한 때의 보험금청구권 또는 매매대금채권을 피압류채권으로 표시한다. 따라서 피압류채권의 표시는 “채무자(매도인) 甲의 제3채무자(매수인) 乙에 대한 유압식프레스기(제조번호 : ○○○-○○,⁷⁷³⁾

772) 이 경우 단지 “임대차계약에 기하여 발생하는 차입채권”으로 기재하면 안 된다. 이는 담보권의 효력이 미치지 아니하는 부분까지 신청하는 것이 되어 부적법하기 때문이다.

773) 동산담보등기사항증명서에는 개별동산으로서 유압식프레스기 제조번호 200으로 되어 있는데, 피압류채권 표시에는 개별동산으로서 유압식프레스기 제조번호 300의 매매대금채권으로 적혀 있다면 이는 부적법한 신청이다.

제조사 : ○○주식회사, 모델명 : ○○○-2001SL) 매매계약에 기한 매매대금채권” 등으로 기재한다.

(3) 집합동산담보권에 있어서는, 예컨대 담보권설정자가 담보목적물[서울특별시 서초구 서초대로 ○○, ○○○호(서초동, ○○빌딩)에 소재하는 노트북 컴퓨터]을 타에 매각한 경우, 앞서 본 대로 당해 목적물의 매각이 통상의 영업범위 내 매각이라면 매매대금에 대한 물상대위는 허용되지 않으나 통상의 영업범위를 초과하는 매각일 경우에는 물상대위가 허용되므로, 그 피압류채권의 표시는 “채무자(매도인) 甲의 제3채무자 乙에 대한 서울특별시 서초구 서초대로 ○○, ○○○호(서초동, ○○빌딩)에 소재하는 노트북 컴퓨터 매매계약에 기한 매매대금채권” 등의 방식으로 기재하면 된다.

5) 신청의 취지 및 이유

신청서에 채권압류를 구하는 취지를 기재하고, 이유에는 채무자가 피담보채권을 변제하지 아니하여 이행지체가 되었다는 사실을 적는다. 이때 피담보채권의 변제기 도래사실의 증명은 필요 없으나 압류신청서에 변제기의 도래사실에 관한 주장은 필요하다. 동산담보권에 기한 물상대위의 경우에도 피담보채권의 변제기 도래를 증명할 필요까지는 없다.⁷⁷⁴⁾ 다만 집합동산담보권에 기한 물상대위의 경우에는 ‘통상의 영업범위를 초과하는 매각’이라는 사실을 주장하여야 할 것이다.

그런데 이 경우 집행법원이 ‘통상의 영업범위를 초과하는 매각’이라는 실체에 관련된 사항을 판단해야 하는 문제가 있다. 이에 관하여는 실무상 신청인은 통상의 영업범위를 초과하는 매각임을 주장하면 족하고 집행을 저지하고자 하는 담보권설정자 등으로 하여금 즉시항고 등으로 불복하도록 해야 한다는 견해(제1설)와 신청인이 통상의 영업범위를 초과하는 매각임을 주장하는 것만으로는 부족하고 그로 하여금 그 사실을 소명까지 하도록 하여 이에 실패하면 압류신청을 기각한 후 기각결정에 대하여 즉시항고로 불복하도록 해야 한다는 견해(제2설)가 나타나고 있다.

6) 그 밖의 사항

신청서에 첨부한 서류의 제목과 통수를 적는다. 또한 신청서를 제출한 신청연월일을 기재하고, 관할법원을 표시하여 신청인 또는 대리인의 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

다. 첨부서류

채권담보권에 기하여 또는 동산담보권의 물상대위에 기한 압류명령을 신청할 경

774) 대법원 1998. 9. 22. 선고 98다12812 판결 참조

우 채권담보권자 등은 집행법원에 담보권, 즉 채권담보권이나 동산담보권의 존재를 증명하는 서류(권리의 이전에 관하여 등기나 등록을 요하는 경우에는 그 등기사항증명서나 등록원부의 등본)를 제출하여야 한다(민집 제273조).

등기사항증명서 외에 채권자와 채무자 사이의 담보권설정계약서, 대출거래약정서, 대출원장 등의 서면을 첨부하면 집행의 신속에 도움이 될 수 있다.

6. 압류절차

채권담보권에 기한 압류절차와 동산담보권에 기한 물상대위 행사를 위한 압류절차는 원칙적으로 금전채권에 대한 강제집행에 관한 규정이 준용되고 있으므로(동산채권담보법 제36조 제3항, 민집 제273조, 민집규 제200조), 이하에서는 압류절차 중 강제집행에 관한 규정을 준용하지 않는 사항을 주로 설명한다.

가. 채권담보권

1) 피압류채권

가) 압류명령의 대상

채권담보권에 기한 압류명령의 대상은 채권담보권의 효력이 미치는 채권에 한정된다.

강제집행의 경우 집행법원은 피압류채권의 존부, 귀속 등에 대하여 심사할 필요 없이(형식적 심사권) 신청인의 주장에 따라 발명하는 것이 원칙이지만, 채권담보권은 등기담보권이고 담보목적물부에 목적채권이 등기된다는 점에서 이를 기준으로 압류명령을 발명하여야 한다. 예컨대, 장래발생채권으로 채무자가 특정된 때에 그 등기된 내용이 “2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 차입채권”으로서 1년분이라면 압류신청서에 발생기간을 한정하여 신청하여야 하고 그렇지 않은 경우 보정명령을 발하여 담보권의 효력이 미치지 아니하는 부분까지 압류하는 일이 없도록 하여야 한다.

담보목적채권이 부동산저당권부 대여금채권인 경우 채권담보권의 효력은 주된 권리인 대여금채권은 물론 종된 권리인 부동산저당권에도 미친다. 이 경우 채권압류 사실을 부동산등기부에 기입하는 규정인 민사집행법 제228조를 이용할 수 있다.

나) 압류금지채권과 압류금지 범위변경

채권담보권의 실행절차에서 채무자의 최저생활보장을 위한 압류금지채권에 관한 민사집행법 제246조 제1항 및 압류금지채권의 범위변경에 관한 같은 조 제3항은 성질상 준용되지 않는다.

다만 압류금지채권 중에는 압류금지와 동시에 담보의 설정도 금지되는 경우(예컨

대, 공무원연금법 제32조, 군인연금법 제7조 등)가 있는데, 이러한 담보설정 금지규정에 위반하여 설정된 담보권은 실체법상 무효이므로 그에 기하여 압류명령을 발령할 수는 없다.

2) 압류경합과 압류의 확장효

담보권 실행 등의 경우에는 담보권자에게 우선권이 있기 때문에 우선변제권의 범위 내에서 담보권자가 우선하게 되므로 압류의 경합(민집 제235조 참조)이 있더라도 담보권자는 전부명령을 얻을 수 있고, 고유의 추심권능에 기초하여 추심권을 행사할 수 있으며, 그러한 우선권 있는 담보권 등에 기초한 압류의 효력도 확장되지 않는다.

3) 피담보채권의 확정

채권자는 채권근담보권을 설정할 수 있다(동산채권담보법 제37조, 제5조). 채권근담보권에 관한 법리는 원칙적으로 부동산근저당권에 관한 법리와 유사하다. 따라서 계속적 거래관계가 종료하거나 근담보권자가 담보권 실행 신청을 하면 피담보채권은 확정된다.

그런데 담보목적물에 대하여 제3자의 압류로 집행절차가 개시된 경우 피담보채권의 확정시기에 관하여 어떻게 볼 것인가의 문제가 있다. 판례는 부동산에 대한 근저당권에 관한 사안에서 매각대금 완납시절⁷⁷⁵⁾을 취하고 있는 반면, 금전채권에 대한 근질권에 관한 사안에서는, ‘근질권이 설정된 금전채권에 대하여 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우 근질권의 피담보채권은 근질권자가 위와 같은 강제집행이 개시된 사실을 알게 된 때에 확정된다’고 하여⁷⁷⁶⁾ 부동산근저당권과 금전채권근질권의 피담보채권의 확정시기를 달리 보고 있다. 담보목적물이 같은 금전채권이라는 점에서 금전채권 근질권과 같이 이해함이 타당할 것이다.

4) 담보목적채권의 확정

가) 담보목적채권이 담보권 설정 당시 이미 채권이 발생한 경우에 해당하는 경우에는 담보목적물의 유동순환이 없으나, 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우 또는 장래발생채권으로 채무자가 특정되지 않은 경우 등의 채권인 때에는 담보목적물의 유동순환을 상정할 수 있다.

그런데 위와 같은 장래발생채권 중 담보목적물의 유동순환이 상정되는 사안에서 담보권자에 의한 담보권 실행 후 또는 담보권설정자에 대한 회생절차 개시결정 후에 발생하는 채권에 담보권의 효력이 미치는가가 문제된다. 이는 유동순환하는 담보목적

775) 대법원 1999. 9. 21. 선고 99다26085 판결

776) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다43621 판결

채권의 확정사유가 무엇이며 확정시점은 언제인가의 문제이기도 하다.

나) 이와 관련하여 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다63836 판결은 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우의 채권으로서 담보목적채권의 추심권을 양도담보권자가 보유하고 있고 유동순환이 허용되지 않은 사안에서 ‘채권양도담보권’의 사적 실행 후 발생하는 채권에 대하여 채권양도담보권의 효력이 미친다고 보고 있다.⁷⁷⁷⁾ 이와 동일한 쟁점은 채권담보권에 관하여도 문제될 수가 있다.

위 판결이 담보권 실행 이후에 발생하는 채권에 대하여 담보권의 효력이 미친다고 한 것은 집합동산에서의 고정화이론을 ‘장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우’에서 채택하지 않은 결과라고 볼 수 있다. 집합동산의 고정화이론에 의하면 담보권자의 실행은 고정화사유에 해당한다고 보아야 하기 때문이다. 다만 담보목적물이 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우이고 양도담보설정자가 추심권을 보유하고 있어 신진대사가 반복되는 순환형에 해당하는 경우에도 위 판례의 법리를 적용할 수 있는지는 현재 단정하기 어렵다. 또한 집합동산의 고정화이론에서는 회생절차개시결정이 담보목적물의 고정화사유에 해당하는지에 관하여 견해 대립을 보이고 있는데, 이 판결은 이에 대한 언급 없이 ‘채무자가 아닌 관리인의 지위에 기한 행위로 인하여 발생하는 것’이라는 점을 논거로 제시하면서 회생절차개시결정 이후에 발생한 채권에 대하여 담보권의 효력이 미치지 않는다고 보고 있다.

다) 위 판결의 취지에 따른다면, 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우 담보목적물의 추심권을 담보권자가 보유하고 있는 때에는 채권담보권 실행 이후 발생하는

777) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다63836 판결【판결요지】[1] 장래 발생하는 채권이 담보목적으로 양도된 후 채권양도인에 대하여 회생절차가 개시되었을 경우, 회생절차개시결정으로 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 및 처분 권한은 모두 관리인에게 전속하게 되는데(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제56조 제1항), 관리인은 채무자나 그의 기관 또는 대표자가 아니고 채무자와 그 채권자 등으로 구성되는 이른바 이해관계인 단체의 관리자로서 일종의 공적 수탁자에 해당한다 할 것이므로, 회생절차가 개시된 후 발생하는 채권은 채무자가 아닌 관리인의 지위에 기한 행위로 인하여 발생하는 것으로서 채권양도담보의 목적물에 포함되지 아니하고, 이에 따라 그러한 채권에 대해서는 담보권의 효력이 미치지 아니한다. [2] 갑이 을 은행으로부터 대출을 받으면서 갑의 국민건강보험공단에 대한 향후 의료비 등 채권을 담보목적물로 한 채권양도담보계약을 체결하였는데, 을 은행이 담보목적물 중 일부인 그 당시 현존 의료비 등 채권에 대하여 담보권을 실행하여 공단으로부터 채권 일부를 회수한 후 갑에 대하여 회생절차가 개시된 사안에서, 을 은행이 피담보채권인 대출금채권 전액의 만족을 얻지 아니한 이상, 담보권 실행 후 발생하는 의료비 등 채권에 대해서도 담보권을 실행할 수 있고, 담보권 실행으로 인하여 그 후 발생하는 의료비 등 채권에 대하여 담보권의 효력이 미치지 아니하게 되는 것은 아니지만, 담보권 실행 후 갑에 대한 회생절차개시 당시까지 담보목적물인 채권이 남아 있지 아니하였고, 회생절차개시 후에 의료비 등 채권이 추가로 발생하였더라도 그러한 채권에 대해서는 더 이상 담보권의 효력이 미치지 아니하기 때문에, 을 은행의 잔존 대출금채권은 담보목적물이 존재하지 아니하는 회생채권이라고 한 사례.

채권에 담보권의 효력이 미친다고 볼 여지가 있다. 그러나 담보권자가 아닌 담보권설정자가 추심권을 보유하고 있을 때에 위 판례의 결론을 동일하게 적용할 수 있을지 여부는 지금 현재 단언하기 어렵다. 장래발생채권으로 채무자가 특정되지 않은 경우에는 담보목적물의 추심권을 담보권자가 보유하고 있는 경우가 적을 것인바, 이에 대하여 위 판례를 적용할 수 있을지 여부 또한 앞으로 검토가 필요한 사항이다.⁷⁷⁸⁾

회생절차개시결정 이후 발생한 채권이 장래발생채권으로서 채무자가 특정된 경우라면 이는 ‘채무자가 아닌 관리인의 지위에 기한 행위로 인하여 발생하는 것’이므로 담보권의 효력이 미치지 않는다. 이는 장래발생채권으로서 채무자가 특정되지 않은 경우에도 동일하게 보아야 할 것이다.

나. 동산담보권에 기한 물상대위

1) 피압류채권

가) 압류명령의 대상 : 물상대위에 기한 압류명령의 대상은 물상대위사유에 따라 다르다. 즉 담보목적물을 매각한 경우에는 매도인이 매수인으로부터 받을 매매대금채권, 임대인 경우에는 임대인이 임차인으로부터 받을 차임채권, 제3자가 불법행위로 담보목적물을 훼손시킨 경우에는 담보권설정자가 그 불법행위자로부터 받을 손해배상채권, 담보목적물멸실을 보험사고로 하여 보험에 가입한 경우에는 담보권설정자가 보험사로부터 받을 보험금청구권이 각 압류명령의 대상이 된다.

채권담보권 중 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우 또는 장래발생채권으로 채무자가 특정되지 않은 경우에는 시기와 종기에 의한 제한을 받는데, 물상대위에 기한 압류의 경우 시기와 종기에 의하여 제한을 받는 경우는 상정하기 어렵다.

집합동산담보권에 기한 물상대위의 경우에 있어서 물상대위원인이 집합동산의 매각이고 통상의 영업범위를 초과하는 매각인 경우에만 물상대위를 허용한다는 입장을 취할 경우, 신청인이 통상의 영업범위를 초과한 매각이라는 사실을 주장할 것인데, 이때 통상의 영업범위 내 처분인지 여부(실체에 관련된 사항)를 형식적 심사기관인 집행법원이 판단하여야 하는 문제가 있고, 이에 관하여 견해가 대립하고 있다는 것에 대하여는 이미 말한 바 있다.

나) 압류금지채권과 압류금지 범위변경 : 물상대위 행사를 위한 압류의 경우에도 압류금지채권에 관한 규정(민집 제246조 제1항)과 압류금지 범위변경에 관한 규정(민

778) 장래발생채권이 아니라 담보권 설정 당시 이미 발생한 채권의 경우에는 이미 발생한 채권이므로 채권담보권 실행 이후에 발생하는 채권을 상정하기 어렵다.

집 제246조 제3항)은 그 성질상 준용되지 않는다.

2) 압류경합과 압류 효력의 확장

이에 관하여도 채권담보권의 경우와 동일하게 보면 될 것이다.

3) 규정상의 문제점

동산채권담보법 제14조는 동산담보권에 기한 물상대위는 압류에 의하도록 규정했지만, 같은 법 제36조 제3항은 채권담보권의 실행을 민사집행법에 의하도록 규정하고 있을 뿐이고, 민사집행법 제273조 제2항, 제3항은 민법 제342조의 질권에 기한 물상대위를 위한 압류절차만을 규정하고 있을 뿐이다.

따라서 동산담보권에 기한 물상대위를 위한 압류절차의 근거규정은 현재로서는 존재하지 않는다. 한편 부동산저당권의 경우에는 민법 제370조에서, 권리질권의 경우에는 민법 제355조에서 민법 제342조를 준용하는 규정을 두어 이 문제를 해결하고 있는데, 동산담보권에 관해서도 이를 참조하여 압류절차의 근거규정을 둘 필요가 있다.

다만 현행법 하에서도 민법 제342조를 유추 적용하여 민사집행법 제273조에 의한 압류를 할 수 있다고 해석이 가능하기는 하다.

다. 집행절차와 등기

1) 채권담보등기기록에의 등기촉탁 여부 : 집행절차에서 등기와 관련하여 피압류채권이 담보목적채권에 해당하든, 피담보채권에 해당하든 채권담보등기부에 압류등기, 말소등기, 이전등기를 위하여 집행법원이 촉탁하는 것은 가능하지 않다. 다만 담보권의 피담보채권이 압류 및 전부명령의 피압류(피전부)채권이 된 경우에는 이는 촉탁에 의한 등기가 아니기 때문에 전부명령 확정증명원 등 서류를 첨부하여 신청에 의해 담보권이전등기를 하는 것은 가능하다.

2) 저당권부채권의 재담보와 부동산등기기록에의 등기촉탁 여부 : 동산담보권부채권이나 채권담보권부채권을 재담보할 수는 없으나(동산채권담보법 제13조), 저당권부채권을 재담보하는 것은 가능하다(민법 제361조).

저당권부채권을 채권담보권의 담보목적채권으로 제공할 경우, 부동산등기기록의 저당권자는 동시에 채권담보등기기록의 담보권설정자가 되고, 부동산등기기록의 채권담보권자(주등기인 저당권에 부기등기하는 형태임)는 동시에 채권담보등기기록의 채권담보권자가 된다. 이 경우 채권담보권자가 채권담보권에 기해 압류 및 전부명령을 받더라도 이를 채권담보등기기록에 압류촉탁등기를 할 수는 없다. 그러나 저당권부채권에 대하여 압류 또는 전부명령을 받을 경우 집행법원이 부동산등기기록에 촉탁등기

하는 것에 관하여는 규정이 있으므로, 저당권부채권에 대하여 압류명령을 받으면 민사집행법 제228조에 의한 압류촉탁등기를 할 수 있고, 전부명령을 받은 경우에는 민사집행규칙 제167조에 의하여 저당권이전의 부기등기가 가능하다.

7. 현금화절차

가. 일반 압류집행에에서 인정되는 추심명령, 전부명령, 특별현금화명령은 채권 담보권에도 준용된다(동산채권담보법 제36조 제3항).

다만 채권담보권자는 피담보채권의 한도에서 채권담보권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있어(동산채권담보법 제36조 제1항), 이행지체 후에는 이미 추심권이 발생되어 있기 때문에 추심권을 부여받기 위한 수단으로 추심명령을 신청할 실익은 크지 않다.

전부명령은 피담보채권의 변제기는 도래하였지만 담보목적채권의 변제기가 아직 도래하지 아니한 경우에 알맞은 채권담보권 실행방법이다. 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 다른 채권자가 압류가압류 또는 배당요구를 한 경우에는 전부명령은 효력을 가지지 아니한다는 민사집행법 제229조 제5항은 전부권자의 독점적 만족을 저지하고 채권자평등주의를 실현하기 위한 규정이므로, 경합하는 다른 채권자에게 채권담보권의 우선변제권을 주장할 수 있는 경우에는 적용되지 아니한다. 예컨대, 채권담보권자 甲의 담보등기일은 2018. 3. 2.이고 채권담보권에 기한 압류 및 전부명령의 제3채무자 송달일은 2018. 7. 2.이라고 할 경우, 일반채권자 乙의 집행권원에 의한 압류명령의 제3채무자 송달일이 2018. 6. 2.이면 甲의 우선변제권 취득일(담보등기일이 기준이므로 2018. 3. 2.)이 乙의 압류명령 발효일(2018. 6. 2.)보다 앞서므로 甲은 乙에 대하여 우선변제권을 주장할 수 있고 전부명령도 유효하다. 이와 달리, 일반채권자 乙의 집행권원에 의한 압류명령의 제3채무자 송달일이 2018. 2. 5.이면 甲의 우선변제권 취득일(2018. 3. 2.)이 乙의 압류명령 발효일(2018. 2. 5.)보다 뒤지므로 甲은 乙에 대하여 우선변제권을 주장할 수 없고(압류에 저촉되는 담보권 취득의 효과), 전부명령도 무효가 된다.

나. 담보목적채권에 조건 또는 기한이 있거나, 반대의무의 이행과 관련하여 있거나 그밖의 이유로 추심하기 곤란한 때에는 법원은 채권자의 신청에 따라 양도명령, 매각명령 또는 관리명령을 하거나 그 밖에 적당한 방법으로 현금화하도록 하는 명령을 할 수 있다(민집 제241조). 이러한 집행법원의 특별현금화명령은 채권담보권자의 신청이

있어야 할 수 있는데, 집행법원은 이 신청을 허가하는 결정을 하기 전에 채무자를 심문하여야 한다(민집 제241조 제2항). 양도명령은 담보목적채권을 법원이 정한 값으로 압류한 담보권자에게 지급에 갈음하여 양도할 것을 명하는 것이고, 매각명령은 법원이 정한 방법으로 추심에 갈음하여 담보목적채권을 매각할 것을 집행관에게 명하는 것이며, 관리명령은 관리인을 선임하여 담보목적채권의 관리를 명하는 것이다.

한편, 지식재산권자가 약정에 따라 동일한 채권을 담보하기 위하여 2개 이상의 지식재산권을 담보로 제공하는 경우에는 특허원부, 저작권등록부 등 그 지식재산권을 등록하는 공적 장부에 담보권을 등록할 수 있고(동산채권담보법 제58조), 이러한 경우 지식재산권의 현금화를 위해 특별현금화명령이 가능하다.

다. 그 밖에 대금완납에 따른 부동산취득의 효과에 관한 민사집행법 제267조는 채권담보권의 실행에 있어서 준용된다.

8. 배당절차

가. 채권담보권에 기한 압류명령을 송달받은 제3채무자가 집행공탁 및 사유신고를 하면 배당절차가 개시되고(민집 제252조), 이 배당절차에는 부동산경매의 배당절차가 준용된다는 점(민집 제256조)에서 집행권원에 기한 일반 배당절차와 동일하다.

다만 채권담보권자는 담보권의 효력이 미치는 범위에서 우선변제권이 인정되고, 압류금지채권에 관한 제한을 받지 않는 점에서 일반 채권자와 다르다고 볼 수 있다.

나. 담보등기부에 등기된 채권에 대하여 집행할 경우 압류명령은 제3채무자에게 송달하여야 효력이 발생하고(민집 제227조 제3항), 담보등기부에 압류등기를 해야 하는 것은 아니다.

다. 일반 압류명령에 기재된 일자가 확정일자가 되므로, 압류명령은 확정일자 있는 증서와 동일하게 취급된다. 동일 채권에 대하여 담보등기부 등기와 민법 제450조 제2항에 의한 통지·승낙이 있는 경우에 다른 규정이 없으면 등기와 통지·승낙의 선후에 따라 우열을 결정한다(동산채권담보법 제35조 제3항). 따라서 일반압류와 채권담보권에 기한 압류가 경합하는 경우에는 일반압류의 제3채무자 송달일과 채권담보등기일을 비교하여 그 우열을 판단한다. 일반 압류명령의 제3채무자 송달일이 채권담보등기보다 빠르면 압류의 처분금지효에 관한 개별상대효 이론이 적용된다고 보아야 할 것이다.

라. 채권담보권자에 대한 구체적인 배당방법은 “제10장 배당등 절차 제8절 배당표의 작성 등 IV. 채권담보권에 대한 배당” 부분 참조.

9. 채권담보권 실행에 대한 불복

가. 채권담보권 실행에 대하여 채무자는 압류요건의 불비 등 절차상 사유와 담보권의 부존재, 소멸 등 실체상 사유를 들어 즉시항고를 할 수 있다(동산채권담보법 제36조 제3항, 민집규 제200조 제2항, 민집 제265조).

동산채권담보법 시행일(2012. 6. 11.) 이후에 최초로 체결한 담보약정부터 그 등기를 할 수 있으므로(동법 부칙 제2조), 그 이전에 체결한 담보약정에 기해 등기한 경우 그 등기는 무효라고 보아야 한다. 채권담보권도 담보목적물인 채권이 소멸하거나 피담보채권이 소멸하는 경우에 소멸하는 것은 부동산저당권과 동일하다(동산채권담보법 제50조 제1항). 존속기간의 만료도 소멸사유가 된다(동산채권담보법 제49조).

나. 양도할 수 없는 채권은 채권담보권의 목적물이 되지 못하므로(동산채권담보법 제37조, 제33조, 민법 제331조), 그러한 채권에 관하여 담보등기를 하더라도 이는 무효이다. 양도금지특약이 있는 채권의 경우 견해의 대립이 있으나, 이에 대하여는 채권담보권을 설정할 수 없고 다만 담보권자가 선의인 때에만 가능하다고 할 것이다. 이 경우 양도금지특약을 들어 담보권자에게 대항하고자 할 때에는 그 자가 담보권자의 악의 또는 중과실을 증명할 책임이 있다고 볼 것이다.⁷⁷⁹⁾

779) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다8310 판결 참조